

初探臺灣原住民族刑事文化抗辯的 適用與意義*

——以花蓮地方法院實證研究為起點

范耕維**、林俊儒***

摘要

本文以臺灣花蓮地方法院為觀察對象，聚焦於法律實踐的觀察與詮釋，初步考察在臺灣刑事審判系統中，法官如何決定文化抗辯的適用與否及其範圍，釐清現行法制如何形塑法官對文化抗辯的適用及其規範意義。首先，透過判決分析與訪談法官及律師，本文發現雖然原住民族與國家法制的文化衝突型態多元，但文化抗辯適用卻侷限於立法者已制定除罪化規定的案件類型。在案件類型的層次

* 投稿日：2023年9月25日；接受刊登日：2024年8月19日。〔責任校對：楊子萱〕。

本文為國科會補助專題研究計畫部分研究成果（計畫編號：NSTC 113-2420-H-259-011），且經國立政治大學研究倫理審查通過（NCCU-REC-202212-E129），作者各司其職貢獻程度相同。感謝兩位匿名審查人提供深入懇切的珍貴意見，提升本文完整性與可讀性。特別致謝何漢葳研究助理的統計諮詢，對法實證研究方法、資料蒐集與分析的指導與批評，令作者獲益匪淺。本文初稿曾發表於2023年台灣法理學會年會，除致謝參與訪談的法官與律師，也感謝謝煜偉教授、吳豪人教授、黃丞儀教授、陳弘儒教授、石忠山教授、王曉丹教授、李明芝教授、許恒達教授、陳惠馨教授、謝孟羽律師、陳冠廷博士生、柯哲瑜Yuri Yuko博士生、林俊宏律師等師友，從本研究開始發想至實際執行與年會報告中提供的寶貴意見與鼓勵。感謝研究助理黃歆甯Canglah、金芊均Langui·Tanapima、郭劉承昊Walis Jiyung的協助。當然，一切文責由作者自負。

** 國立東華大學法律學系副教授。

*** 國立政治大學法學博士。

穩定網址：<https://publication.iias.sinica.edu.tw/03805152.pdf>。



呈現出法院文化想像完全趨同於立法部門的現象。接著，本文也發現在設有除罪化規定的案件類型中，法官對該規定成立要件的理解會因案件類型而有別，進而影響法官適用文化抗辯時，選擇減刑或無罪的判決路徑。關於要件解釋層次中法官文化想像趨同於立法程度不一的現象，本文認為源自於法律規範規制力強度的差異，可能與要件保護利益態樣、法律規定明確性、要件數量、要件實質內涵等因素相關。

關鍵詞：文化抗辯、原住民族、文化趨同、森林採取、野生動物獵捕、槍枝持有、法實證研究、法律與社會。

目次

壹、前言	肆、文化抗辯要件理解的實證考察：以案件事實為中心
貳、問題起源：從文化抗辯理論出發	一、森林產物採取的文化想像：以森林法第15條第4項理解為中心
一、理論回顧：文化抗辯理論與研究位置	二、野生動物獵捕的文化想像：以野保法第21條之1理解為中心
二、本土課題：臺灣原住民族與文化抗辯	三、槍枝持有使用的文化想像：以槍砲條例第20條理解為中心
參、文化抗辯適用範疇的實證考察：以案件類型為中心	四、要件理解實證結果的規範意義
一、文化抗辯的實證研究取徑與方法	伍、結論
二、文化抗辯適用範疇及界限的實證觀察	
三、適用範疇實證結果的規範意義	

壹、前言

本文主題是當臺灣法官在刑事審判中面對原住民被告刑事文化抗辯（下稱：文化抗辯）的主張或相關規定時，從法官對適用與否及其範圍的決定中，初探法官對原住民族文化的想像形貌，並嘗試釐清現行法制形塑該想像的運作機制。研究動機則是在現行法制提升對原住民族文化尊重的發展中，觀察法官在司法場域中對原住民族文化的理解，分析該理解的形塑過程與對認事用法的影響，釐清司法機構與原住民族文化間的相互關係。

具體言之，呼應憲法增修條文第10條第11項及第12項揭示的尊重多元文化理念，原住民族基本法（下稱：原基法）第30條揭示司法程序中應尊重原住民族語言、傳統文化及習俗的精神。而此精神能否實現，無論是讓原住民被告不因語言、文化而影響其司法近用，或是使原住民族文化能在司法程序中影響認事用法與裁判結果，法院體制與法官皆具高度影響力¹。換言之，正如John Upton的田野調查指出，司法機構與法庭空間、語言、經濟因素等，同為影響臺灣原住民被告司法近用的重要因素²，本文認為原住民族文化特殊性能否被納入認事用法中並影響判決，法官對此面向同樣具高度影響力。至於在法官認事用法與裁判中，與原住民族文化最密切相關，最能呈現出法官如何在國家法與原住民族文化衝突間理解該文化者，當屬法官如何適用「文化抗辯」（cultural defense）。

文化抗辯是源自美國審判實務用以排除刑責的抗辯事由。當個人行為選擇植基於文化背景或特殊慣習時，基於對多元文化的尊重，該具特殊族群或文化背景之人，因該背景或慣習所為之行為，

¹ 湯文章，原住民族在訴訟法上地位之研究，憲政時代，31卷1期，頁39-41、50-51（2005年）。

² J. Christopher Upton, *From Thin to Thick Justice and Beyond: Access to Justice and Legal Pluralism in Indigenous Taiwan*, 47 LAW & SOC. INQUIRY 996, 1016-20 (2022).

與現行法規發生衝突而符合犯罪構成要件時，可透過主張此事由來阻卻刑責成立³。由於目前為我國所適用而源自西方現代法治的法體制，並未將原住民族社會具有「法的確信」的慣習與規則加以國家法化、權利化⁴，當原住民族文化慣習屬於被刑法禁止且可科以刑罰的行為時，該慣習與國家法間極易產生文化衝突。因此，向來多有主張將文化抗辯概念導入我國刑法體系，並嘗試在犯罪階層中尋找安置此概念的體系位置，使原住民族文化實踐行為可能構成現行刑法罪名時，有提出此抗辯來減免刑責的可能⁵。而從當前發展來看，也確實可觀察到文化抗辯內涵實質上實現於我國刑事立法與審判實務的現象：一方面，審判實務中已可見被告提出採集或狩獵行為出於文化慣習，影響法官論罪科刑而被評價為文化抗辯運用的案例；另一方面，以森林法第15條第4項、野生動物保育法（下稱：野保法）第21條之1等立法為例，這些法官可用來認定被告特定行為得阻卻違法之依據，同樣被評價為實質上將文化抗辯概念納入立法所形成之除罪化規定⁶。

關於上開理論與立法現況，相關國內文獻可謂汗牛充棟。然而，這些文獻主要集中在他國理論引介及我國原住民族犯罪與重要判決之現況分析⁷，或討論如何將該理論整合至我國刑法體系與

3 ALISON D. RENTELN, THE CULTURAL DEFENSE 6 (2004).

4 王泰升，論台灣社會上習慣的國家法化，臺大法學論叢，44卷1期，頁54（2015年）。

5 許恒達，國家規範、部落傳統與文化衝突——從刑法理論反思原住民犯罪的刑責問題，台灣原住民族研究季刊，6卷2期，頁47-75（2013年）。

6 王皇玉，原住民犯罪的文化抗辯及其實踐，臺灣原住民族法學，1卷1期，頁32、43（2016年）。

7 王皇玉，原住民犯罪的文化困境與除罪化，收於：刑罰與社會規訓——台灣刑事制裁新舊思維的衝突與轉變，頁207（2009年）；參見王皇玉，原住民持有槍械問題之研究，台灣原住民族研究季刊，5卷1期，頁1-37（2012年）（以下簡稱：王皇玉，2012）；王皇玉（註6），頁31-44；張宏節，非法獵捕保育類野生動物判決之實證研究——以原住民文化抗辯為中心，法律扶助與社會，1期，頁31-69（2018年）；許恒達，刑法秩序與多元文化：以東亞刑事法院為中心的考察，收於：葉俊榮編，變遷中的東亞法院：從指標性判決看東亞法院的角色

法律解釋⁸。換言之，針對文化抗辯在我國法院如何被法官實際適用之研究，及以之為基礎的本土政策建議或理論建構，目前仍有待進一步發展。從理論發展來說，他國對文化抗辯的採用與否，早已跳脫肯否立場擇一的二元邏輯，即令是以肯定文化抗辯為前提的理論，也對文化抗辯是否確實保障原住民族文化慣習的正面效果提出質疑，甚或提出修正現有肯定立場的批判性見解。因此，以目前文獻討論為基礎，在我國立法與法院實際運作脈絡下，嘗試建構本土理論應有其必要。此外，與理論層面相呼應，在原住民族文化保障與文化抗辯理想落實的實踐層面，縱使法規制度上肯認文化抗辯適用，現實上仍須依靠法官承認個案有適用可能，並透過判決作出相應的文化論述，才能在刑事審判系統中真正落實對原住民族文化慣習的尊重。如此一來，我國法院適用文化抗辯的現況為何，包括適用案件的比例、類型、法律要件之解釋與法律效果的選擇等，是否符合尊重原住民族文化慣習之理論預設，勢將成為另一個疑問。

特別是，臺灣當代法制度繼受自歐陸法系並以成文法典為框架，有其制定法解釋適用方式⁹，與淵源於英美法系而作為當代文化抗辯理論發展基礎的墾殖者國家（如：美國、加拿大及紐澳）間，無論是實體法所採犯罪階層、程序法所採證據法規則、承認文化抗辯並制度化的立法模式皆有別。因此，文化抗辯在臺灣刑事審判的適用狀況，即可能出現截然不同的故事版本。以此為前提，在我國成文法規範與法庭活動參與者的交互作用下，呈現出何種文化

與功能，頁107-146（2016年）。

8 參見王皇玉，原住民犯罪與不法意識之研究——兼評新竹縣尖石鄉風倒木竊取案件，收於：刑罰與社會規訓——台灣刑事制裁新舊思維的衝突與轉變，頁251-279（2009年）；許恒達，持有獵槍、獵捕保育類野生動物與原住民慣習間的衝突及解套：評宜蘭地方法院104年度原訴字第1號刑事判決，臺灣原住民族法學，1卷2期，頁49-60（2017年）；許恒達（註5），頁47-75；參見樓一琳，原住民族文化抗辯於我國刑事司法體系之應用兼論原住民族司法諮詢委員會之地位，臺灣原住民族法學，7期，頁112-131（2021年）。

9 王泰升，建構台灣法學：歐美日中知識的彙整，頁492-495（2022年）。

抗辯適用樣貌，自有觀察之必要。而且，此觀察也會反饋至源自他國的文化抗辯理論，成為形塑本土理論的基礎。

自上開問題意識出發，首先本文將以我國現有文獻討論為基礎，從單純承認文化抗辯與否的討論，進一步踏入文化抗辯的影響與效果、其如何詮釋文化內涵等議題的理論思辨，觀察這些理論如何理解文化抗辯在審判系統中對文化內涵的形塑，如何描述此形塑機制的生成，以及如何評價或批判這套形塑機制。透過理論爬梳，將使本文觀察重點具體化：文化抗辯如何在我國刑事審判系統中被法官適用？產生哪些後續效應？這些觀察的理論意義為何？（本文貳）。接著，雖然文化抗辯實際適用所呈現的樣貌，可能透過實體法及程序法規範、法官審理與律師辯護等因素，由特定成文法規範及行動者所決定，但考慮法官是最直接適用文化抗辯與解釋其內涵者，故本文將以法官對文化抗辯的適用作為觀察中心。對此採取事實證研究方法¹⁰，透過對刑事判決的量化分析，結合質化訪談與文化抗辯適用最相關的法官與律師，嘗試描述文化抗辯適用的經驗性事實。根據這些經驗面向的觀察，賦予其規範性意涵，從臺灣版故事之發掘拓展至臺灣版理論之建構（本文參、肆）。最終，將以前開研究成果為基礎，指出後續政策研究方向（本文伍）。

貳、問題起源：從文化抗辯理論出發

在此先回顧文化抗辯理論的發展，除指出得否適用的爭議及如

¹⁰ 本文以司法機構與原住民族文化的相互關係為關照對象，偏向「法與社會研究」(social-legal/law and society) 取向之實證研究。關於實證研究取向See HERBERT M. KRITZER, ADVANCED INTRODUCTION TO EMPIRICAL LEGAL RESEARCH 21-22 (2021); Peter Cane & Herbert M. Kritzer, *Introduction* to THE OXFORD HANDBOOK OF EMPIRICAL LEGAL RESEARCH 1, 4 (Peter Cane & Herbert M. Kritzer eds., 2010).

何透過解釋學援用的討論外，由於文化具有多重意義，且是在相互連動的刑事審判系統內部，經由不同法庭活動參與者的演繹與實踐呈現，故評價文化抗辯如何形諸於法律與社會的關係之中，也將是理論的關鍵面向。以此為前提，再於臺灣脈絡下，提出在文化抗辯本土實踐之中具有理論意義的課題。

一、理論回顧：文化抗辯理論與研究位置

文化抗辯可理解為文化證據之提出與評價的體系，刑事法庭在何種前提及要件下得加以適用，始終存在理論爭議，迄今仍爭論不休。反對者認為，法律給予不同文化經驗者不同待遇，將破壞法律的普遍性而威脅正義¹¹。亦有主張認為，文化抗辯可能過度美化非國家法律¹²，複製以文化為名的支配關係，維護既得利益並保留文化內部的從屬邏輯¹³。反之，支持者則從多元文化主義出發，認為採用文化抗辯才能符合罪刑相當的要求，且可避免套用不適合的司法解釋來追求正義¹⁴。

Alison Renteln在2004年出版的《文化抗辯》（THE CULTURAL DEFENSE）中，總結了早期關於文化抗辯的辯論。她以文化作為身分的組成為基礎，主張多元文化社會應支持多重身分，並確保其享有尊嚴與權利。據此，文化抗辯不僅能達成這項目標，也符合包括罪刑相當及適當刑法評價在內的刑事司法原則¹⁵。就如對刑罰制裁採取嚇阻理論，也並非毫無區別地給予徒具形式平等的懲罰，行為

11 See Julia P. Sams, *The Availability of the "Cultural Defense" as an Excuse for Criminal Behavior*, 16 GA. J. INT'L & COMP. L. 335, 335-54 (1986).

12 See Marc Galanter, *Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law*, 13 J. LEGAL PLURALISM & UNOFFICIAL L. 1, 1-47 (1981).

13 See Doriane Coleman, *Individualizing Justice through Multiculturalism: The Liberals' Dilemma*, 96 COLUM. L. REV. 1093, 1093-1167 (1996).

14 See Alison D. Renteln, *A Justification of the Cultural Defense as Partial Excuse*, 2 S. CAL. REV. L. & WOMEN'S STUD. 437, 437-526 (1993).

15 RENTELN, *supra* note 3, at 187-94.

人的主觀理解也應被納入刑罰制裁的考量項目¹⁶。因此，貶低或忽視特定文化實踐本身不僅不公平，也不會因此使得刑事審判更為公平。再者，文化抗辯不見得損害弱勢群體權利，該抗辯也可以為弱勢群體所用，故應於運用過程之中審視各方利益為判決，而非自始排除其適用。**Renteln**認為：一旦阻絕文化抗辯適用在刑事司法中，反而會使刑罰對社會復歸目的之追求，轉變為具有強迫色彩的同化政策¹⁷。

在關於適用與否的理論對立之外，有另一支對文化抗辯的討論聚焦在文化抗辯的實踐（包括：適用對象、案件及其傳達群體的形象表徵），特別是牽涉到主流社會如何運用與評價文化抗辯。舉例而言，文化抗辯的主張繫於文化證據，而文化證據可能不得不以符合主流社會對於特定文化形象理解的方式呈現，這不免使文化抗辯的主張流於某種本質主義¹⁸。而此種主流社會的影響，甚至形成一種「代言」而忽視文化的細膩差異，讓文化抗辯成為刻板印象的總和¹⁹。在此過程之中，可能進一步產生「文化趨同」（**cultural convergence**）的現象：當主張文化抗辯的理由與主流印象相近時，該理由較可能受到法庭接受並獲得較輕的判決，但此結果將反過來限制文化抗辯的適用範圍²⁰。

上述理論指出實踐面向對於文化抗辯理論思辨的重要性，也突顯出理論思辨已不侷限於肯否之爭。亦即，不論性質上是否為國家法，即使是文化慣習，實踐上也可能產生強化主流刻板印象與產生支配關係的現象。故當法規範的實踐可能存在或產生支配關係時，

¹⁶ *Id.* at 195-97.

¹⁷ *Id.* at 197-98.

¹⁸ See Leti Volpp, *Blaming Culture for Bad Behavior*, 12 YALE J.L. & HUMAN. 89, 89-116 (2000).

¹⁹ ANNE PHILLIPS, MULTICULTURALISM WITHOUT CULTURE 81-82, 84, 96 (2007).

²⁰ See Cynthia Lee, *Cultural Convergence: Interest Convergence Theory Meets the Cultural Defense*, 49 ARIZ. L. REV. 911, 911-59 (2007).

即使理念上反對單一的國家法，也不代表應無條件擁抱非國家法，或認為文化得不經論證、在法庭上不受任何質疑。正如Melissa Demian「沒有文化，就沒有抗辯」的主張，認為要先理解文化「如何」透過實踐被描述、形塑與發展，才能檢討文化抗辯理論適用的正當性，進而將研究重點從「法律本體」轉向至「法律實踐」²¹。或者，抱持類似關懷，而在理論上對文化抗辯採否定態度的Anne Phillips也曾提到：相較於文化抗辯相關的法學論理，在文化抗辯實踐中，呈現文化抗辯的語言及其如何詮釋文化內涵，可能是更為迫切的課題。同時，應藉此觀察性別或階級等面向，與文化不同程度的連動關係，以獲得更為全面的評價²²。

事實上，這種關注實踐面向而超越肯否之爭的進路，已成為當代文化抗辯理論的主奏。舉例來說，因為文化抗辯呈現於司法程序，而司法程序使用的法庭語言又受到語言形塑機制影響，故文化抗辯的肯否論辯即難以掌握文化抗辯的全貌，而有必要將觀察視野涵蓋至該形塑機制。如Sigurd D'hondt即注意到這個問題，故將語言分析結合民族誌方法，觀察律師如何使被告在司法程序成為知識對象，透過去個性化、將客戶轉化為民族誌知識對象的方式等，讓文化差異成為「可見」的機制，以尋求司法裁判的接納並獲得文化抗辯的法律效果²³。或如Anthony Good則從包括專家證人在內的刑事證據切入，觀察人類學家及其知識如何被法庭考慮，從法庭推理及運作中，檢討文化證據的呈現及其與文化權間的關係²⁴。

21 Melissa Demian, *Fictions of Intention in the "Cultural Defense"*, 110 AM. ANTHROPOLOGIST 432, 437-39 (2008).

22 PHILLIPS, *supra* note 19, at 99.

23 See Sigurd D'hondt, *The Cultural Defense as Courtroom Drama: The Enactment of Identity, Sameness, and Difference in Criminal Trial Discourse*, 35 LAW & SOC. INQUIRY 67, 67-98 (2010).

24 See Anthony Good, *Cultural Evidence in Courts of Law*, 14 J. ROYAL ANTHROPOLOGICAL INST. S47, S47-60 (2008).

總結對當代文化抗辯理論的觀察，值得注意的重點有二：第一，文化抗辯的法庭實踐對理論建構來說，具有高度重要性；第二，文化抗辯的樣貌，是透過現行法規、法庭內外參與者的語言及行動邏輯、審判制度等因素的交互作用而形成。而此發展也呼應本文對法律與文化在實踐中相互影響的理解：法律由社會建構而反映社會文化與價值，但也透過人與法律程序、機構的連結而形塑文化與社會價值²⁵。因此，呼應此研究進路，本文將跳脫純理論層次的肯否爭議，而以文化抗辯的法庭實踐作為研究的焦點，嘗試觀察刑事法庭如何認知文化差異，並透過指認生產法學知識的形塑機制，描述「（有資格成為文化證據並連結特定法效果的）文化想像」。以下，本文嘗試從本土課題切入，具體化本文探問的對象。

二、本土課題：臺灣原住民族與文化抗辯

呼應1980至1990年代的臺灣原住民族權利運動與正名運動，1994年憲法增修條文將「山胞」改稱為「原住民」，並在1997年將「原住民族」正式寫進憲法，承認原住民族作為政治與法律上主體。在2005年制定之原基法，更透過具有法律位階的規範制定，以積極態度落實原住民族權利。不過，即使原住民族權利被積極地明文於法規，司法實務仍面臨多重的挑戰²⁶，其中，又以文化抗辯最受矚目：原住民族依循其傳統慣習或部落經驗之行為與刑事法規衝突時，該如何是好？

代表案例如下：2003年鄒族達邦社頭目發現外人持有蜂蜜時予以留置，遭判以搶奪罪，其抗辯即是行使頭目之管理權限²⁷；2005

25 Lynn Mather, *Law and Society*, in THE OXFORD HANDBOOK OF POLITICAL SCIENCE 289, 289 (Robert E. Goodin ed., 2011).

26 蔡志偉 (Awi Mona)，從客體到主體：臺灣原住民族法制與權利的發展，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1530-1534（2011年）。

27 案例事實與歷審見解可參照：臺灣嘉義地方法院92年度簡字第1064號刑事判決、臺灣嘉義地方法院92年度簡上字第151號刑事判決。指出鄒族文化與國家

年泰雅族司馬庫斯部落將颱風吹倒的櫟木用於部落造景，搬運者們卻被判以竊取森林主產物罪，族人認為這項行為已經部落會議決議，並不是竊取的行為²⁸；2011年排灣族舅公用手撫摸男童睪丸（阿力力）遭以加重強制猥褻罪起訴，行為人主觀上認為這是依照習俗對晚輩表達關心之意²⁹；2013年布農族獵人以拾獲的土製長槍及子彈獵捕山羌及長鬃山羊供母親享用，卻被判以非法持有槍枝罪及獵殺保育類野生動物罪³⁰。

在上述案例中，文化抗辯均成為被告的法庭主張，而要透過何種刑事法學的論理來行使文化抗辯，在不同案件類型、不同法學主張之下，可看到不同的論點：有認為因原住民族人實行行為時的規範意識有別，欠缺遵守法律之期待可能性而否定其罪責³¹；亦有認為原住民依其信仰或部落慣習所為者，在符合若干前提之下，得認定為良心犯，作為阻卻違法或減輕罪責事由³²。這些對於文化抗辯的不同釋義推理，具有其規範上的重要意義³³。但如前述有關研究焦點的說明，本文不再關注法解釋學推理之中關於肯認文化抗辯與

法衝突可見於：雅柏甦詠·博伊哲努（Yapasuyongu Poiconu）、楊曉珞，文明社會的野蠻誠命：從嘉義地方法院九十二年度簡上字第一五一號判決談鄒族傳統財產權，台灣原住民族研究季刊，5卷3期，頁134（2012年）。

28 案例事實與歷審見解可參照：臺灣新竹地方法院96年度易字第4號刑事判決、臺灣高等法院96年度上訴字第2092號刑事判決、最高法院98年度台上字第7210號刑事判決、臺灣高等法院98年度上更（一）字第565號刑事判決。

29 案例事實與歷審見解可參照：臺灣臺東地方法院101年度侵訴字第8號刑事判決、臺灣高等法院花蓮分院101年度侵上訴字第47號刑事判決。

30 案例事實與歷審見解可參照：臺灣臺東地方法院102年度原訴字第61號刑事判決、臺灣高等法院花蓮分院103年度原上訴字第17號刑事判決、最高法院104年度台上字第3280號刑事判決、最高法院106年度台非字第1號刑事判決、司法院釋字第803號、最高法院111年度台非字第111號刑事判決，本案文化衝突與文化權利討論可見於：蔡志偉（Awi Mona），從「王光祿釋憲案」論原住民族狩獵文化權利的憲法保障，臺大法學論叢，51卷3期，頁687-746（2022年）。

31 王皇玉（註6），頁33-35。

32 許恒達（註5），頁76-77。

33 相關討論：范耕維，森林法第15條第4項傳統領域概念之適用與檢討：評最高法院109年度台上字第3148號刑事判決及其歷審判決，法律扶助與社會，9期，頁31-32（2022年）。

否及其體系定位的討論，而將進一步聚焦在文化抗辯的實踐：無論基於阻卻違法或減輕罪責，是在法規範與法庭活動的何種互動中推理出判決有關論罪科刑之結論，進而建構出臺灣當下原住民族文化抗辯的法律秩序？

此外，作為一篇非為研究其他國家的問題而努力的論文³⁴，本文期望在臺灣繼受歐陸法律體制與作為成文法典國家，且已存在文化抗辯明文化之法規範的前提下，嘗試自此特點進行文化抗辯本土實踐的觀察，乃至於理論建構。如學者許恒達即曾據此特點提出之猜想：繼受德國刑法體系的東亞刑事法院，始終以立法實證性為標準，僅存在成文規定或權威判決先例的情況下，才承認文化因素有影響刑責的可能，文化因素須透過犯罪成立要素來作成有利於行為人之解釋，才有減免刑責的可能³⁵。這正表現出臺灣與文化抗辯理論發展主流的國家背景相異——原住民族的身分及政治處境與移民有著不同的文化抗辯論證途徑，且適用案件範疇聚焦於自然資源利用類型而有差異——的特點，而在提問及研究設計時應予注意，同時也呈現本研究價值所在。以下，本文以三個問題為討論對象：

1. 問題一：法院對文化抗辯的適用範疇為何，以何種案件類型為適用對象？此現象中法規範與法庭活動間的關係為何，有何規範意義？
2. 問題二：法院在不同案件類型中適用文化抗辯成文化的法規範時，對規範要件的理解為何，以何種案件事實態樣作為適用對象？以何種判決路徑賦予法律效果？此現象中法規範與法庭活動間的關係為何，有何規範意義？
3. 問題三：透過上述二問題對臺灣文化抗辯實踐的觀察，是否存在文化抗辯與主流社會、立法者文化想像趨同的現象？其形塑機制與理論意義為何？

34 此學術現象描述，見：吳聰敏，台灣經濟四百年，頁513（2023年）。

35 許恒達（註7），頁137。

透過三個提問，本文欲初探「臺灣版」的文化抗辯的適用及其意涵。同時，須注意到本文的研究設計及其侷限：第一，文化抗辯的實踐是由多元的法庭活動參與者，以及司法養成、法庭運作等司法制度交互作用而成。為能抽絲剝繭各因素在文化抗辯本土實踐中的相互關係，本文會先聚焦在最直接決定文化抗辯適用狀況的法官部分；第二，臺灣存在數條實質上將文化抗辯透過立法成文化的「除罪化規定」，其適用方式除了辯護人主張後由法官被動適用外，法官也可主動依職權適用之，故本文所指稱的「適用文化抗辯」泛指上述主動與被動適用的情況。同理，凡是判決顯示認事用法過程中，被告與辯護人曾提出犯罪與文化因素相關之抗辯，或法官主動討論除罪化規定及圍繞於此之考量適用與否者，皆屬本文所稱「與文化抗辯相關聯」之情形。

參、文化抗辯適用範疇的實證考察：以案件類型為中心

此部分首先要觀察法官適用文化抗辯的案件範疇。關於這項問題，受訪法官們的發言似乎呈現出存在一個法院系統有共識、可一望即知的判準：

「遇到有文化抗辯的狀況，其實大部分法官都心裡有個底啦。」(J3)³⁶

「其實卷宗有足夠多的暗示，這個案件是跟原住民有關。」(J2)

36 針對訪談的5位法官、5位律師（2位女性、8位男性），本文分別以代碼J1至J5、L1至L5稱呼。

然而，這些發言觸發更多疑問：何謂「跟原住民（文化）有關」的案件類型？什麼樣的案件會使「法官都心裡有個底」可能成立文化抗辯？法官們適用文化抗辯的範疇何在？對此，本文以「設有除罪化規定」、「原基法第19條規定的利用行為」及「不設案件類型限制」，區分三種不同範疇，呈現立法及司法互動所形塑的文化抗辯適用案件類型為何，並嘗試說明此適用範疇如何在立法與法院交織作用中形成，以及其呈現的現象有何規範意義。

一、文化抗辯的實證研究取徑與方法

前部分提出的三個問題，包括法官適用文化抗辯的案件類型、個案事實態樣，以及與立法間的關係，都環繞一個主軸：作為法官適用文化抗辯的基礎，其對原住民族的法官文化想像。因此部分牽涉實踐層面，故本文選擇透過對法院判決與法庭活動參與者的實證觀察，嘗試從法官如何適用文化抗辯的經驗性事實中，描繪其在刑事案件中對原住民族文化想像的圖像及形塑機制，據此詮釋其規範意義並嘗試理論化。

呼應釐清法官文化想像之研究目的，本文觀察重點有二：第一，釐清法官肯定文化抗辯適用的範圍與界限，亦即探討法官針對何種案件類型會肯定文化抗辯之適用；第二，針對森林法、野保法、槍砲彈藥刀械管制條例（下稱：槍砲條例）等案件類型，釐清法官適用文化抗辯所考量的因素。針對第二點，在我國已有將文化抗辯成文化的除罪化規定的前提下，可透過觀察法官對除罪化規定中文化抗辯成立要件（下稱：除罪化要件）內涵的理解，來嘗試描述法官肯定文化抗辯、承認犯罪事實與文化存在關聯的案件事實態樣為何。

此外，在對經驗性事實的觀察中，有兩個因子是必須注意的。其一是除罪化規定的有無與規定之制定可能影響法官對文化抗辯的適用範疇與標準，故必須將此種立法前後的狀態納入觀察視野。其

二是法官肯認文化抗辯適用後賦予法律效果的路徑選擇。當從法官對文化抗辯的適用標準與範疇來分析法官文化想像時，由於法官在適用後會根據不同路徑賦予案件有罪、無罪或減刑等強弱程度不同的法律效果，該路徑選擇及其與除罪化規定間的相互關係，也可能反映法官想像上的差異，而有納入觀察的必要。

以下，本文欲透過對原住民被告刑事案件中法官認事用法與論罪科刑之觀察來描繪其文化想像。對此，考量刑事判決係法官對於當事人文化抗辯主張之總結性評價，法官對該主張的肯否與考量因素，反映其文化想像及文化抗辯的形塑機制，故對判決為量化分析有其必要。然而，由於量化分析難以掌握審判的全部維度，面對判決的形成、決策所涵蓋之法律分析的豐富性，其分析有其限度³⁷。就如文化抗辯作為司法論述，是由法庭活動參與者、訴訟制度及法規範等背景的交互作用所形成，若僅對判決進行量化分析，可能無法充分釐清這些交互作用的樣貌。亦即，從觀察完整性出發，對法庭活動者的調查、對判決文字的分析，都是不容忽略的面向。因此，本文決定選擇取徑於對判決之量化分析及對法庭活動參與者的訪談，分別勾勒出兩個視角下對法官文化想像內容與形塑過程的觀察，再根據篇幅考量與主題設定，綜整二組觀察中有關文化抗辯的部分，嘗試進行現象分析，從而說明其規範意義。

首先，在判決量化分析的部分，為盡可能擴大觀察樣本，避免有案件未上訴之情形，以及為求法院對犯罪事實為完整陳述，避免一部上訴而減少陳述範圍，故以地方法院判決為觀察對象。接著，考量截至2023年3月底的內政部人口統計，原住民人口數以花蓮縣居全國第一，佔全體原住民人口數的17%，以及財團法人法律扶助基金會原住民族法律服務中心截至2018年底的資料顯示，花蓮縣受

37 Gregory C. Sisk, *The Quantitative Moment and the Qualitative Opportunity: Legal Studies of Judicial Decision Making*, 93 CORNELL L. REV. 873, 886-89 (2008) (book review).

扶助原住民族當事人數佔全體扶助人數17%，亦為全國第一³⁸。加上該縣行政區全部皆屬原住民傳統居住而具原住民族歷史淵源及文化特色，經中央原住民族主管機關報請行政院核定之「原住民地區」。故本文決定以臺灣花蓮地方法院（下稱：花蓮地院）判決為主要分析樣本。據此，本文自司法院資料開放平臺獲取「各級法院之終結案件資料」與「裁判書」之檔案，並針對1999年至2023年3月花蓮地院判決文本（text）中的犯罪事實、判決理由、論罪科刑等資料進行人工方式篩選與編碼，結構化為可供軟體程式分析之結構化資料（structured data）³⁹，進行判決分析工作。

接著，為理解法庭活動參與者對於經驗現象賦予之意義，亦進行質化研究。考慮檢察官雖有客觀性義務，但基於對抗性立場，通常不會主動提出文化抗辯，文化抗辯主張往往存於被告、辯護人與法官認事用法。因此，本文從目的抽樣，根據研究對象特徵，選出得以對前述主題提供豐富資訊的受訪者時，即以曾於花蓮地院擔任二年以上原住民專業法庭（股）法官5人，以及曾以花蓮地院為執業範圍二年以上律師5人（為兼顧多元性及專業性，其中2人為財團法人法律扶助基金會原住民族法律服務中心專職律師以經辦文化抗辯案件為職責者）共10人作為研究對象。其來源以滾雪球方式招募，透過熟識者推薦尋得。訪談時會徵得受訪者同意，並依照通過研究倫理審查之方法進行，盡可能減少對於研究對象的風險。至於研究資料分析，則採紮根理論（Grounded theory）之方式，透過開放性編碼、主軸編碼及主題編碼，使得訪談資料特徵明顯化，以該段落內容對比其他段落或其他受訪者，觀察文化抗辯是在何種案件審理過程生成。這項研究方法適合於尚未廣泛研究而複雜的領域，

38 謝孟羽、張靖珮，臺灣原住民族之法律扶助，2018法律扶助國際論壇，財團法人法律扶助基金會主辦，頁6-7（2018年11月1日至11月3日）。

39 判決文本結構化之討論：何漢葳，應作迴歸觀：資料、不確定性與人工智慧法學，收於：李建良編，研之得法：中央研究院法律學研究所成立十週年文集，頁723-726（2021年）。

以探究理論發展的可能性。據此進行取樣，將範疇明確連結的概念結合一起予以概念化，形塑出理論樣貌。這部分質化研究的成果將與量化分析結合，相互對照勾勒法官的文化想像及其形塑機制。

最終，作為以描述法現象、法論證為主的實證研究形式⁴⁰，上述研究設計能使法官文化想像的圖像更清晰，同時有助於理論建構⁴¹，但也仍有其侷限。詳言之，本文考量族群及部落間文化慣習有別，各行政區環境差異也會影響犯行態樣⁴²，故將觀察範圍先限定於單一行政區之花蓮地院審理及判決。誠然，不同族群與區域間的比較有其研究價值，而且限制在單一法院會產生研究結果無法直接推論至全臺各法院的研究侷限。但是，使森林產物採取、野生動物獵捕與槍枝持有使用等行為置於相似的族群與環境因素下觀察，除可避免直接分析全國性資料可能忽略臺灣相異族群、部落、環境的高度歧異，也可以更清楚釐清特定法院對於特定管轄區域案件的認事用法情形。而此優點也有助於後續設計全國範圍的實證分析或跨區域比較研究。另外，從作為邁向全國法院整體研究的第一步來看，對原住民族人口數最多且設有原住民族專業法庭的花蓮地院，進行文化抗辯審理現象的觀察與分析，除有大量樣本可供初步發掘實務運作下值得注意的問題點，研究結果也有助於重新梳理問題意識、指出對其他法院的觀察重點，並且提供延伸後續研究的實證基礎，而具有學術價值。因此，本文衡量之後，即先以花蓮地院關於文化抗辯之審理為研究對象，下文所稱法院、法官與律師皆以花蓮地院為指涉範圍。

40 張永健，實證研究在法學中的角色，收於：法實證研究：原理、方法與應用，頁109-110（2019年）。

41 實證研究此功能 See Joshua B. Fischman, *Reuniting 'Is' and 'Ought' in Empirical Legal Scholarship*, 162 U. PA. L. REV. 117, 157-58 (2013).

42 以森林採取為例，花東地區可能因物種分布、部落活動傳統型態等因素，採取產物偏向真菌類與蘭科植物，但如桃竹地區則集中在紅檜、肖楠、楓、櫟木。而此物種差異，自然也造成採取手段、目的差異，形成不同區域間犯行態樣的差別。

二、文化抗辯適用範疇及界限的實證觀察

本段針對第貳部分提出的問題一，將探問法官會於何種案件類型中肯認文化抗辯之適用，嘗試釐清法官適用文化抗辯的範疇與界限。如圖1所示，根據本文對判決內容、法官與律師行動的後設（meta）觀察，分別以2004年森林法、野保法與2001年槍砲條例等除罪化規定之修法，及2005年原基法的立法為界限，由小至大設定三個可能的文化抗辯適用範疇：A.以修法設有除罪化規定之案件類型為界限的「立法除罪範疇」；B.以2005年原基法第19條適用類型為界限的「基本法規定範疇」；C.欠缺明文規定但可能在司法場域中被承認的「非明文範疇」。在這三個範疇中，A與B分別代表了立法者對原住民族文化不同界限與寬窄的理解，而C則代表了廣於立法者想像界限的文化理解。

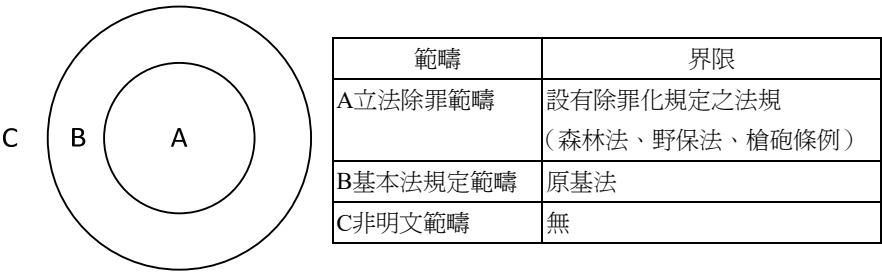


圖1 文化抗辯適用範疇分類

資料來源：自行繪製。

以下，本文將結合法院判決及法庭活動參與者訪談意見，對三個範疇進行說明。除透過判決分析法官在除罪化規定及原基法立法後，適用文化抗辯的案件類型範圍，以及在現行刑法體系下適用文化抗辯的取徑，觀察法官文化想像與立法者想像（下稱：立法想像）間的關係。同時也透過質化訪談的資料，說明法庭活動參與者對文化抗辯適用範疇與取徑的觀察與理解，及其行動在實際的案件

範疇形成中所扮演的角色。藉此說明來釐清文化抗辯實際上的適用範疇，以及法規範與法庭活動在此現象中的關係。

（一）立法除罪範疇

在2005年原基法第19條第1項規定承認原住民族自然資源利用權之前，立法者已於2001年至2004年針對常因文化衝突而生的「森林產物採取」（下稱：森林採取）、「獵捕野生動物」與「獵槍持有使用」（下稱：槍枝持有）等三種犯罪行為類型⁴³，增訂除罪化規定。總結來說，這三種類型連同原住民族採取土石行為在內，這些具尊重原住民族文化而排除刑事處罰意涵的規範，至少包括：槍砲條例第20條、野保法第21條之1、森林法第15條第4項，以及採取土石免申辦土石採取許可管理辦法（下稱：土石管理辦法）第2條⁴⁴。

1. 鳥瞰文化抗辯案件類型分佈

由於上開除罪化規定的立法源自各具體行為類型與原住民族文化間的連結，故可謂其反映出一種以個別具體行為類型作為文化抗辯適用範疇的想像。而這種立法者對原住民族文化行為類型，採最具體但界限最緊縮的理解，即本文所稱「立法除罪範疇」。在此脈絡下，當各條除罪化規定指出可依明文規定適用文化抗辯的各種特定案件類型之後，法官實際適用文化抗辯的案件類型為何，是否侷限於存在除罪化規定的類型，就成為值得觀察的對象。以下先鳥瞰2004年至2023年花蓮地院法官回應被告主張或本身認事用法時，有就文化抗辯進行論述，亦即有討論原住民族文化與論罪科刑間關係的案件類型。

⁴³ 王皇玉，文化衝突與臺灣原住民犯罪困境之探討，臺大法學論叢，36卷3期，頁273-290（2007年）。

⁴⁴ 王泰升，台灣法律史上的原住民族：作為特殊的人群、地域與法文化，臺大法學論叢，44卷4期，頁1682-1683（2015年）。

從下表1可知，僅觀察法官曾對文化抗辯作出論述的案件類型時，其範疇並未限於目前已存在除罪化規定者，包括醉態駕駛（下稱：酒駕）、財產犯罪⁴⁵、侵入住居、妨害投票與水土保持等，皆是目前尚未存在除罪化規定的類型。不過，由於表1未考量法官最終判決結果與上級審是否維持等因素，故僅能反映法庭活動中因被告主張或法官認事用法，而於判決呈現出曾論及文化抗辯的案件類型。對此，透過表2依判決路徑區分，在表1範圍內曾論及文化抗辯的案件判決中，法官考量文化抗辯而判決無罪者（下稱：無罪路徑）佔12.54%，判決有罪但部分接受文化抗辯而將文化因素納入量刑考量者（下稱：量刑路徑）佔65.02%，亦即肯認文化抗辯適用者佔全體相關判決的77.56%⁴⁶。自本文目的來看，這些肯認文化抗辯的判決，即可能分析出法官適用文化抗辯案件類型的範疇，而適於作為分析法官適用界限與立法除罪範疇間關係時的觀察對象。

45 此處財產犯罪包括：臺灣花蓮地方法院97年度易字第275號刑事判決中公用地放牧墾殖之竊佔行為（刑法第320條第2項）、臺灣花蓮地方法院101年度簡上字第56號刑事判決中破壞他人財物之毀損行為（刑法第354條）、臺灣花蓮地方法院106年度花原易字第5號刑事判決中海邊撿拾漂流木之侵占脫離物行為（刑法第337條）。

46 因我國刑事判決會清楚區分論罪與量刑的段落。故可清楚判斷法官是在論罪段落中，適用如「依法令行為」來阻卻違法並諭知無罪，或在量刑段落中將原住民族文化因素納入判斷。在後者中，當法官提到犯行出於「傳統狩獵習慣」、「生活慣俗」、「傳統謀生習性」、「家族世代傳承」及「傳統文化」等關鍵字句時，因明確指出基於文化考量而影響量刑，故該案件即可歸類於量刑路徑。

表1 論及文化抗辯之案件類型分佈

案件類型	案件數	%
醉態駕駛	153	50.50
獵槍持有使用	60	19.80
獵捕野生動物	43	14.19
森林產物採取	22	7.26
礦物土石採集	10	3.30
妨害投票	6	1.98
財產犯罪	5	1.65
水土保持	2	0.66
侵入住居	2	0.66
總計	303	

資料來源：作者自製。

表2 論及文化抗辯之案件判決結果

判決結果	案件數	%
無罪	38	12.54
有罪但量刑考量	197	65.02
單純有罪	68	22.44
總計	303	

資料來源：作者自製。

2. 文化抗辯無罪路徑類型及其上訴結果分佈

首先，以表1案件為範圍，可看到下表3顯示的是法官採無罪路徑的案件，其中佔73.68%是屬於法官適用除罪化規定阻卻違法而諭知無罪。至於不存在除罪化規定，但法官仍透過阻卻罪責或透過解釋更上位的原基法規定，來適用文化抗辯並諭知無罪者，則僅佔全體案件的26.31%。

表3 文化抗辯無罪路徑案件類型分佈

存在除罪化規定	案件數(%)	案件數	%
是		28	73.68
獵捕野生動物	4 (10.53)		
獵槍持有使用	19 (50.0)		
礦物土石採集 （土石管理辦法第2條）	3 (7.89)		
侵入住居 （原保地管理辦法第8條）	2 (5.26)		
否		10	26.31
礦物土石採集 （原基法第19條）	5 (13.16)		
妨害投票	2 (5.26)		
竊佔	3 (7.89)		
總計	38	38	

資料來源：作者自製。

根據表3，可以說法官適用除罪化規定阻卻違法且採無罪路徑者，主要是適用前開提及的野保法第21條之1、槍砲條例第20條與土石管理辦法第2條等規定。較特別的是花蓮地院107年度原易字第86號刑事判決中，被歸類為侵入住居的二個案件，法官適用2019年修法刪除前的原住民保留地開發管理辦法（下稱：原保地管理辦法）第8條，認為原住民被告係基於該辦法行使原住民保留地（下稱：原保地）上合法耕作之權利，出於正當理由路經附連圍繞他人土地，不構成刑法第306條「無故」之違法性要件而無罪⁴⁷。事實上，此種犯罪行為與原保地法規相關的「原保地使用」案件類型

47 臺灣花蓮地方法院107年度原易字第86號刑事判決：「考量原住民保留地之成因與規範，認（被告）依當時情狀，出於使用其具有使用人之法律上地位之466號土地之目的，因無其他通行路線，經過當時尚未裝設門柵之469號土地上之庭院、菜園等附連圍繞之土地，為有正當理由，並非無故，無從構成第306條之侵入附連圍繞土地罪……。」

中，也可觀察到法官同樣是透過適用該辦法之明文規定，肯定文化抗辯而阻卻違法並諭知無罪的現象。

相對地，在未能適用除罪化規定而法官仍適用文化抗辯的少量案件中，可看到兩種採取無罪路徑的論述進路。其一是採取解釋適用原基法的進路，如花蓮地院105年度原訴字第67號刑事判決中，法官認為原住民被告違反礦業法第69條未取得礦業權而私自採取玫瑰石，係於原住民地區基於非營利目的採集自用，屬於傳統慣習的表現而適用文化抗辯，故在該法無除罪化規定的狀況下，依原基法第19條法理論知無罪。其二是論述阻卻罪責的進路，如同樣可歸類為原保地使用類型的花蓮地院97年度易字第275號刑事判決中，雖然無明文規定可承認被告墾殖行為合法，但法官採納文化抗辯，認為被告因信賴原保地編定政策而欠缺刑法第16條之不法意識，從阻卻罪責的路徑諭知其無罪。此二部分由於與基本法規定範疇及非明文範疇相關，故留待後文詳述。

接著，若將上開現象對照本文對案件適用所劃分的三個範疇來理解時，對比立法除罪範疇內之案件佔全體無罪案件的73.68%，屬於基本法規定範疇與非明文範疇者，則分別僅佔13.16%與13.15%。據此，單純觀察一審法院適用文化抗辯而諭知無罪的判決時，明顯呈現出的現象是，大多數法官僅在立法者明文制定除罪化規定的案件類型中，肯定原住民被告的犯罪行為適用文化抗辯的可能，並直接適用除罪化規定作為阻卻違法的論據，根據刑法第21條「依法令行為」來諭知無罪⁴⁸。至於立法者未制定除罪化規定，須法官透過解釋原基法或論述阻卻罪責，才可能諭知無罪的案件類型，則鮮少成為法官適用文化抗辯的對象。如此一來，或可歸納出一審法官適用文化抗辯且採無罪路徑的案件類型，明顯限定在立法除罪範疇中的結論：若要賦予無罪的法律效果，多數案件被限定在立法承認除

48 許恒達（註5），頁60。

罪化的案件類型，僅少數承審法官嘗試突破根據立法想像所劃下的界限，擴大承認文化抗辯適用的案件類型。

然而，本文認為若要更全面觀察法院對文化抗辯適用範疇的理解，尚需進一步將這些無罪判決經檢察官上訴至二審後的結果也納入觀察，才能描繪出司法機構中文化想像的完整圖像。對此，下表4顯示在28件法官適用除罪化規定諭知無罪的案件中，有約60.71%的17件為檢察官提起上訴，其中16件二審維持一審判決，僅有1件獵槍持有使用案件為二審撤銷並改判有罪。簡言之，檢察官對此類型上訴的案件中，佔94.12%的絕大多數無罪判決皆為二審所維持。至於唯一一件被二審改判有罪者，則肇因於法院對原住民族獵槍持有行為存在分歧的文化想像，導致對作為槍砲條例第20條之除罪化要件的「供作生活工具之用」，存在寬嚴不同的理解，此部分留待後述（肆、三）。至於10件法官未適用除罪化規定而諭知無罪的案件中，有8件被檢察官提出上訴，且全部皆為二審撤銷而獲得不予維持的結果。

表4 文化抗辯無罪路徑案件檢察官上訴結果

存在除罪化規定	上訴數	維持(%)	未維持(%)
是	17	16 (94.12)	1 (5.88)
獵捕野生動物	3	3	0
獵槍持有使用	9	8	1
礦物土石採集 （土石管理辦法第2條）	3	3	0
侵入住居 （原保地管理辦法第8條）	2	2	0
否	8	0 (0)	8 (100)
礦物土石採集 （原基法第19條）	5	0	5
妨害投票	0	-	-
竊佔	3	0	3

資料來源：作者自製。

總結上開觀察可歸納出：一審適用文化抗辯而論知無罪判決者，大多數皆為立法設有除罪化規定的案件類型，僅少數屬於不存在除罪化規定之案件類型。而當檢察官上訴時，前者幾乎皆為上級審所維持，後者則全部皆為上級審不予維持。此現象或可理解為法院適用文化抗辯且採無罪路徑的案件類型，透過一審法官認事用法與上級審審查機制，已被完全限定在立法除罪範疇中，未能突破至基本法規定乃至於非明文範疇。簡言之，關於賦予無罪效果的文化實踐行為，法院文化想像被侷限在立法想像範圍內。

3. 文化抗辯量刑路徑類型及其上訴結果分佈

接著，目光轉向法官適用文化抗辯但僅採量刑路徑的案件類型。下表5顯示在表1範圍內屬此類型的案件中，案件類型屬於森林法、野保法及槍砲條例等存在除罪化規定者佔21.32%。同時，表6則顯示雖然這些案件多數未被檢察官繼續上訴二審，但即使是極少數被上訴的2件案件，皆獲得上級審維持原審判決的結果。相對於此，如酒駕與妨害投票等案件類型非屬明文設有除罪化規定者，則佔此類型案件數的78.68%。不過，雖然此類型同樣僅有極少數4件案件被檢方提起上訴，但全部皆於上級審獲得不予維持的結果。

表5 文化抗辯量刑路徑案件類型分佈

存在除罪化規定	案件數 (%)	案件數	%
是		42	21.32
獵捕野生動物	27 (13.71)		
獵槍持有使用	7 (3.55)		
森林產物採取	8 (4.06)		
否		155	78.68
妨害投票	2 (1.02)		
醉態駕駛	153 (77.66)		
總計	197	197	

資料來源：作者自製。

表6 文化抗辯量刑路徑案件檢察官上訴結果

存在除罪化規定	上訴數	維持(%)	未維持(%)
是	2	2 (100)	0 (0)
獵捕野生動物	1	1	0
獵槍持有使用	0	-	-
森林產物採取	1	1	0
否	4	0 (0)	4 (100)
妨害投票	2	0	2
醉態駕駛	2	0	2

資料來源：作者自製。

以上觀察結果有兩點應注意。第一，單純由案件數來看，適用量刑路徑的案件中，似乎呈現立法未設除罪化規定的案件類型案件數遠大於設有除罪化規定者之現象。然而，應注意佔適用量刑路徑案件數77.66%的153件醉態駕駛案件，全部都是由同一位法官在簡易判決處刑程序的獨任制審理過程中，於被告未主動提出文化抗辯的前提下，自行認定有文化抗辯適用而作成判決。換言之，若將此單一法官試圖以個人文化想像突破立法者所設界限的情況扣除，則未設除罪化規定但法官仍適用量刑路徑的案件數僅剩2件投票行賄案件。第二，若將上級審判斷納入考量，呈現出與無罪路徑類型相同的觀察結果，亦即存在除罪化規定的案件類型中，法官適用文化抗辯之決定皆為上級審維持。反之，欠缺除罪化規定類型的判決皆為上級審撤銷而不予維持。故如表7所示，不區分法官適用文化抗辯後採取的判決路徑，存在除罪化規定的案件類型的判決僅1件為上級審撤銷不予維持。反之，未設除罪化規定案件類型中，法院判決全數獲得上級審撤銷不予維持的結果。此觀察結果再次反映出，目前法院適用文化抗辯案件類型被限定於立法除罪範疇，呈現其文化想像被立法想像所框限的「立法除罪範疇限定現象」。

表7 法官適用文化抗辯案件檢察官上訴結果

存在除罪化規定	上訴數	維持(%)	不維持(%)
是	19	18 (94.74)	1 (5.26)
否	12	0 (0)	12 (100)
總計	31	18	13

資料來源：作者自製。

4. 立法除罪範疇限定現象與立法實證性的關聯

判決分析指出的「立法除罪範疇限定現象」中，顯示法官多半僅在立法者明文制定除罪化規定的案件類型，才會適用文化抗辯。呈現法官文化想像受限於立法想像的現象。而從論知無罪的狀況皆以明文除罪化規定為依據，取徑刑法第21條「依法令行為」來阻卻違法觀之，此一現象有可能呼應學者許恒達的猜想，亦即法官文化想像受依循「立法實證性」認事用法影響，僅立法肯認行為與原住民族文化有關聯而明文制定除罪化規定的類型中，才有適用文化抗辯的可能。以下，結合訪談資料，可以更清楚觀察到法官適用文化抗辯侷限於立法除罪範疇與立法實證性間的關係。

「真正有遇到這種文化抗辯，或是跟他們族群文化有關聯性，其實不多啦。那大部分會遇到的，大概就是槍砲，或者是那個野生動物保育法或森林法，大概就是這些狀況比較會遇到啦。」(J2)

「是不是法律有明文規定當然要注意嘛，就是那個這段沒有規定阻卻違法事由。」(J5)

「原則上，在這種立法者已經預設在原住民族這樣的族群，他有比較多的除罪化事由的時候呢，可能就要預先收到案件的時候的人就要先預想到說，這案件的性質上，是不是會涉及到原住民族的問題。」(J2)

「大概是這一塊我們需要去查些什麼，所以也不用等到說……不用等到辯護人或是不用等到被告自己去抗辯這些事情，其實我們心裡都有數，大概會去調查這些。」(J3)

上述訪談中，受訪法官明顯地受除罪化規定的影響，表明當法律明文規定這些特定的阻卻違法事由時，在審判活動中方會予以注意，不待律師抗辯即會主動調查相關事證，並認為「這些狀況」才與原住民族文化有關而有適用文化抗辯的可能。換言之，第參部分開頭提到，有法官受訪時提及對文化抗辯「都心裡有個底」，指的正是存在除罪化規定的案件類型。

由此觀之，文化抗辯適用被限定於立法除罪範疇，並取徑「依法令行為」來阻卻違法，與法官依循立法實證性認事用法間有所關聯。正因如此，當可作為成文阻卻違法事由的除罪化規定，對法官適用文化抗辯範疇具影響性，進而催生「立法除罪範疇限定現象」時，此現象暗示在以下二個範疇中值得觀察的面向：當缺乏除罪化規定使法官無法適用成文阻卻違法事由時，可能難以適用文化抗辯，進而限縮其適用範疇。

(二) 基本法規定範疇

原基法第19條承認原住民族基於生活慣習與傳統文化，享有合法利用自然資源的權利，故此規範除涵蓋立法制定除罪化規定之案件類型外，更可擴及其他符合本條要件的自然資源利用行為。正因如此，法院如何理解此基本法規定的性質，是否將文化抗辯適用擴及至無除罪化規定適用，但為本條規定所涵蓋的案件類型，是觀察文化抗辯實際適用範疇時的重要面向。

1. 基本法規定性質之爭：作為廣義除罪化規定？

正如有律師(L4)在訪談提到：「如果只是純用現在已經有除罪化的法規去看的話，那根本就幾乎很多案子都不用打了」。面對

文化抗辯適用被限定於立法除罪範疇的現象，原基法第19條承認原住民族合法利用自然資源權利的內涵，提供了律師透過廣義解釋此規定來主張文化抗辯的空間。如以下訪談資料所示，面對法官依循立法實證性適用文化抗辯的傾向，當律師們主張文化抗辯時，根據立法精神廣義解釋原基法規定成為其嘗試的破口。

「說實話，水保法就沒有啊；森林法有，對不對？然後土石採取法有；礦業法勉強算有；然後野保法有；可是國家公園法沒有啊。」(L1)

「原基法第34條第2項，第34條1項叫他們要在三年內修正，如果修正前要由中央原住民族主管機關會同目的事業主管機關作合法原則解釋適用。」(L3)

「其實當然最好就是有關的都要依原基法第34條全部修法嘛，但是這個這輩子都沒有可能。」(L4)

「所以變成就是說把原住民族基本法的精神把它融入到這個法律構成要件裡面，去做一個盡量寬鬆的解釋這樣子。」(L4)

特別是如多數受訪律師都提到的，包括水土保持相關的土地利用、國家公園中採集狩獵等自然資源利用型態，理應依原基法第34條要求制定或修正相關法律，但有因立法怠惰而未能落實之嫌，導致現行除罪化規定未能涵蓋所有可能源自於原基法的文化抗辯案件類型。正因如此，有律師就主張法院應基於原基法精神，在現行刑法體系下寬鬆解釋文化抗辯的適用，亦即主張以原基法規定為適用範疇。在此脈絡下，原基法第19條性質成為法庭論辯的爭點之一，也牽動著法院是否將文化抗辯適用範疇予以擴張。

對此，從以下受訪法官的意見可看出，關於是否能根據原基法的抽象規範，將文化抗辯積極解釋適用於無法援引除罪化規定的具

體案件，存在著見解歧異。有些法官認為，這是可行做法，主張文化抗辯適用範疇至少要跟原基法第19條的適用範圍相同，呈現出擴張文化抗辯適用至基本法規定範疇的傾向（如J4）；但有些則認為現行除罪化規定已相當充分，對於援引基本法作為除罪化規定來阻卻違法抱持保留意見，偏向維持立法除罪範疇的立場（如J3）。

「以這個東西作為一個解釋的原則，一個上位的解釋原則，然後呢，在這個有關於森林法或者是礦業法，甚至是所謂的這個槍砲彈藥條例的相關的解釋的時候，就不能夠比這個來得小，所以他們的除罪化範圍要比這個……至少要相同這樣子。」（J4）

「我覺得以目前規範來說，大概該有的……就刑事案件來說，大概該有的保障，我認為算是夠的。」（J3）

2. 以基本法主張文化抗辯之判決觀察

若將目光轉向原基法通過至2023年3月底花蓮地院曾論及文化抗辯之案件，只根據原基法第19條提出文化抗辯相關主張者，僅佔全體案件量1.98%的6個案件。而且，這些案件不是直接被法官否定原基法規定作為除罪化規定，無法阻卻違法而獲得有罪判決，就是一審根據原基法規定阻卻違法諭知無罪後，該見解為上級審否定，導致判決遭撤銷而不予維持的結果。

前者如花蓮地院101年度簡上字第56號刑事判決，對於毀損鄰居鐵皮屋頂致令不堪使用的犯罪事實，被告抗辯：自身權益遭侵害時，依部落習俗應先自行排除侵害，且司法程序依原基法第30條應尊重該傳統習慣，故不應負毀損刑責。對此，該判決認為原基法僅保障原住民享受權利，並無得以其習俗阻卻違法的明文，同時提到刑事法僅承認原住民在歲時祭儀的獵捕與森林採取行為應受保障，否定被告文化抗辯而判決有罪。可以說此判決清楚呈現出否認原基

法規定作為除罪化規定的立場，拒絕文化抗辯適用擴及基本法規定範疇，將其限定於立法除罪範疇。

後者如原住民族人採集玫瑰石遭檢察官以礦業法第69條第1項私自採礦罪予以起訴的「玫瑰石私採案」⁴⁹。一審的花蓮地院105年度原訴字第67號刑事判決以被告係於原住民地區非營利採集自用，在立法者尚未對該法提出修法前，可適用原基法第19條為由諭知無罪判決⁵⁰。案件經檢方上訴二審後，臺灣高等法院花蓮分院106年度原上訴字第37號刑事判決持不同立場，認為原基法是在規範特定領域政策的抽象基本原則，不具規範具體權利義務關係之性質，故不得適用原基法作為裁判請求之依據，因而將基於原基法適用被告文化抗辯的一審判決撤銷⁵¹。依該二審見解，若無訂定除罪化規定就等同於不存在阻卻違法的空間。從此案歷審發展來看，可讀出區別「個別法規除罪化規定」與「原基法規定」性質差異，呈現將文化抗辯適用範疇限定在除罪化規定內的狀況。

3. 基本法規定範疇實證觀察之發現

由於原基法第19條具有「並非針對特定案件類型制定之除罪化規定，但表明對原住民族自然資源利用文化的尊重」的特質，使其規範性質與法院適用存在歧見。但正因如此，觀察法院如何處理依原基法規定主張之文化抗辯，可更清楚釐清法院實際適用文化抗辯的範疇與在刑法體系下的適用取徑。

49 此規定已於2023年礦業法全文修正時，移至同法第77條第1項。

50 臺灣花蓮地方法院105年度原訴字第67號刑事判決：「所為合於原住民族基本法第19條規定，不具有違法性及可罰性，而屬刑法第21條第1項所規定之依法令行為，自屬不罰，依首揭規定及說明，自應為被告5人無罪判決之諭知。另主管機關業已提出前述礦業法修正草案，仍有賴立法機關權衡上述之權益衝突後，針對各情而妥適修法，供各機關及原住民族成員遵循，以免類此爭議再生。」

51 臺灣高等法院花蓮分院106年度原上訴字第37號刑事判決：「當非獨尊原住民族文化之保護或站在轉型正義立場，即一律除罪，或逕行套用原基法第19條之要件，不區分前開相異之價值取向，而一體適用在所有對應之相關法規上……。」

首先，從「玫瑰石私採案」顯現的一、二審見解分歧中，可發現一審是將原基法第19條理解為除罪化規定，故採集行為依刑法第21條「依法令行為」阻卻違法而無罪。反之，二審則否定該原基法規定為除罪化規定，故採集行為非屬「依法令行為」而無法阻卻違法。此一分歧顯示出法院系統其實是依循「有除罪化規定，故可適用文化抗辯阻卻違法」的邏輯，根據除罪化規定的有無來決定是否適用文化抗辯。如此一來，更凸顯出法院適用文化抗辯的範疇，受其認事用法依循立法實證性之影響。

接著，當法官依循立法實證性，普遍強調必須個別法規設有除罪化規定才可阻卻違法時，即便原住民族所為資源利用的權利已為原基法肯認，只要未對特定行為類型設除罪化規定，仍然無法在阻卻違法層次成功主張文化抗辯。具體來說，自原基法第19條觀之，與獵捕、森林採取同屬資源利用行為之列，第1項第3款「採取礦物」就尚未直接在立法層次制定相應的除罪化規定。此外，若將土地也納入自然資源利用範圍，包括水土保持法及國土計畫法都可能與自然資源利用相關。但以水土保持法為例，族人若未依原保地管理辦法取得土地所有權或使用權，即令其行為主張是利用祖先遺留土地，仍構成水土保持法第32條之非法墾殖、占用致水土流失罪⁵²。

以上狀況呈現出在立法者未設除罪化規定的情況下，由於法官存在將文化抗辯適用侷限於立法除罪範疇的傾向，即使同屬原基法第19條的資源利用行為，因該案件的爭議處於基本法規定範疇，故要被適用文化抗辯仍有困難。換言之，只有在立法者明文承認特定

52 臺灣花蓮地方法院105年度原訴字第103號刑事判決：「被告之祖先就本案土地於79年3月26日前已開墾之事實，縱然屬實，然被告於103年10月間起至104年3月間，在本案土地並未登記任何權利，有前揭建物查詢資料在卷可憑，依上開規定，即難認有合法使用權限。則被告既未在本案土地申請登記耕作權或地上權，即屬未經本案土地所有權人即國財署之同意而占用、經營及使用，自具有主觀不法犯意及實質違法性，其有違反水土保持法第32條第1項前段之事實已明……。」

行為類型與原住民族文化的關聯，並據此制定除罪化規定的狀況下，被告援引此除罪化規定來指出犯罪行為與文化慣習的關聯，所提出的「直接抗辯」，會被法院接受並連接到阻卻違法的效果。反之，在欠缺除罪化規定可直接引用，故無法提出直接抗辯的案件類型中，被告僅能透過原基法規定或文化衝突相關事證，先論述犯罪行為與文化慣習的關聯後再提出的「間接抗辯」，則無法連接至阻卻違法效果，也難以被法院肯認⁵³。

最後，在上開脈絡下，針對立法未設除罪化規定的案件，由於要透過間接抗辯來主張阻卻違法並推導無罪的路徑存在障礙，當法院認為被告行為欠缺可罰性時，只能轉而使用較迂迴的論述。如銅門竹屋竊佔判決即從主觀構成要件著手，以族人長期佔有並使用該等土地，且經部落會議決議通過可為使用作為證據，證明原住民族人無從知悉或可得而知該土地為國有地，論述其不成立竊佔罪⁵⁴。這正是取徑於構成要件的法律解釋，在現行刑法體系下透過論理使被告獲得實質上等同原基法第19條之保障。在訪談中也有律師已觀察到此現象：

「只有19條看起來有賦予原住民一個比較具體的除罪化，或是一個具體的請求權，或者是行使的權利等等，可是我其

53 直接抗辯的邏輯可用「除罪化規定（行為與文化相關）→文化抗辯（阻卻違法）」來理解。間接抗辯則可用「原基法規範／文化衝突事實→行為與文化相關→文化抗辯（無法阻卻違法）」來理解。二者差異在於作為文化抗辯基礎的「行為與文化關聯性」，於前者已被立法承認，故被告可無需證成就直接援用來抗辯，後者則因欠缺立法承認，故被告須先證成後再提出抗辯。

54 臺灣花蓮地方法院106年度原易字第250號刑事判決：「其等在法律上雖無權利任意將本案土地授權與銅門部落會議用以興建本案竹屋，但其等主觀上確實認為對於本案土地有合法利用之權利。被告或其他部落會議之成員，自可能因認○○○、○○○及祖先等人長期利用本案土地耕作，確為本案土地之地主，故徵求其等同意始決議在本案土地上興建本案竹屋。況在部落會議討論中因上開情形而也沒有提及本案土地可能為國有地或河川區域之情事，衡情尚無不合理之處，應屬誤信有法律上原因而予佔有之情形，亦無從遽認被告知悉或可得而知本案土地為國有地河川區域甚明。」

實沒有這麼覺得啦。其實原基法其他條文，我覺得還是可以去解釋出，如果要等於阻卻違法事由我覺得是有空間的。對，但是其實實務上基本上不太這樣做，那他反而會……就像我講的去用刑法三階去論這樣子。」(L5)

此提及「用刑法三階去論」，透露的訊息正是：在違法性階層主張文化抗辯的路徑，可理解為已被除罪化規定獨占的狀況下，未被視為除罪化規定的原基法第19條，難以被法官所接受作為阻卻違法事由。此狀況連帶影響到刑事審判實務以其他刑法階層的阻卻主觀構成要件、阻卻罪責等，作為適用文化抗辯或否定行為可罰性的路徑。

(三) 非明文範疇

事實上，在各條除罪化規定及原基法第19條中所關注的自然資源利用行為之外，根據以下訪談意見，可能還有「隱性」、「非直覺」而不屬於自然資源利用的其他行為類型，可能在刑事審判中得適用文化抗辯而值得關注。本文將此部分稱為「非明文範疇」。

「可能具有部落會議的決議去使用，或是依照傳統觀念去使用，但是卻認為他是在竊佔國土，或者是認為他違反了這個水土保持法。像這類案件，就是它又比較隱性一點，不像那種資源利用的一般自然資源，就是水資源啦、森林資源啦、狩獵啦，或是採取礦石，這種比較直覺性，現在大家可能比較了解的。」、「所謂的原住民的文化性這件事情，我會覺得他應該不限於所謂阻卻違法，或是主觀犯意的欠缺啦，就是意圖、故意或過失……不只是這樣子，我覺得文化性是存在每一個可能性的，即便當一般的傷害案件，那背後的成因，如果具有一個文化性，我會覺得他就是一個原住民的特殊案件。」(L1)

不過，雖然從法理推論此範疇可能涵蓋眾多案件類型，但根據對判決的觀察，實際上並非如此。由下表8可知，目前非屬自然資源利用而適用文化抗辯之案件類型，僅有妨害投票與酒駕。惟如前述，這些類型案件若為檢方上訴時，全部都面臨上級審不予維持的結果。接著，雖然在適用文化抗辯案件中，屬於自然資源利用者僅佔33.19%，低於非屬自然資源利用的66.81%。但是，細究非自然資源利用行為之案件組成，可發現多數皆為前面提及由特定一位獨任制法官在簡易程序中對酒駕案件所為者。設若扣除此狀況，非自然資源利用類型者僅有佔文化抗辯案件1.7%的妨害投票案件。換言之，若非這位法官對酒駕背後的文化因素情有獨鍾，非自然資源利用可能適用文化抗辯的案件比例極低。

表8 自然資源利用行為與文化抗辯適用

自然資源利用行為	案件數(%)	無罪(%)	量刑路徑(%)
是	78 (33.19)	36 (94.74)	42 (21.32)
否	157 (66.81)	2 (5.26)	155 (78.68)
妨害投票	4	2	2
醉態駕駛	153	0	153
總計	235	38	197

資料來源：作者自製。

實際上，在判決分析可見的「酒駕」及「妨害投票」外，訪談資料中反覆提及的「制度衝突」、「儀式評價」及「原住民身分」等案件類型，也都可看見不同於原住民族自然資源利用的描述，可作為理解非自然資源利用文化抗辯的重要面向，也是以下主要討論對象。

1. 酒駕類型

本文觀察範圍內適用文化抗辯的酒駕案件，皆由特定一位獨任制法官做成，其考量「居住區域」與「教育程度」等面向，基於原住民族文化受社會經濟結構影響，文化與地理環境致其規範意識難以內化，故做成減刑判決⁵⁵。雖然這些判決中，少數被上訴二審後皆不被維持，但作為以判決回應「原住民族與物質使用關係」者，仍深具觀察價值。具體來說，在153件案件中，全體被告皆居住於該法官認定為非都會區的花東，且如表9所示有62.75%的被告教育程度為未取得高中職及專科學歷，可看出該法官描繪的酒駕背景因素：多數居住於花東且特定學歷程度以下之原住民被告，可能因地理、資源等環境因素形塑其物質使用之文化、習慣，進而有透過量刑路徑適用文化抗辯的可能。此外，該量刑路徑的選擇也反映其未將酒駕理解為法秩序認可的行為，而是在責任階層中以文化因素對期待可能性的影響為論述基礎。

⁵⁵ 如臺灣花蓮地方法院104年度原花交簡字第189號刑事判決：「出生及其所居住之花蓮縣秀林鄉，地理環境並未等同人口稠密的都會區，供公眾運輸之交通工具並不發達，以機車代步已為多數人之生活型態，而被告本身所受之國民義務教育僅達國小畢業之程度，對於立法者欲以重刑嚴罰方式達到減少酒駕造成人身傷亡之意旨，囿於經年累月的成長背景、文化以及環境因素，難以立即於其內心的心理系統層面形成一定程度的規範意識。……不論是山地、平地原住民本身均存在屬於原住民族文化及生活習慣受到社會政經結構因素影響之問題，亦即非原住民族文化系統之一般人對於原住民愛飲酒的刻板印象，實係存在國家對於酒類採行公賣制度、資本主義市場系統的強勢行銷運作以及原住民與其家族親友間行為網絡等因素之影響，促使原住民飲酒的文化習慣，從傳統神聖祭典儀式性文化轉變成現代社會所認知的日常世俗性生活的行為文化，而此原住民習以為常的飲酒行為，在現今社會政經結構處於弱勢的環境中，亦帶有面對現今社會結構中強勢的文化以及法律規範採取自我逃避的意涵。」

表9 酒駕適用文化抗辯案件被告教育程度

教育程度	案件數	%
國小畢業	13	8.50
國中肄業	7	4.58
國中畢業	45	29.41
高中職・專科肄業	29	18.95
高中職・專科畢業	30	19.61
大學畢業	1	0.65
未提及（智能障礙）	2	1.31
單純未提及	26	16.99
總計	153	

資料來源：作者自製。

若將上述分析對照訪談資料，無論法官或律師，接受訪談時也都會論及酒駕現象的背景因素。差別僅在於，部分受訪者呼應上述判決分析，提到公共交通資源匱乏的問題，並且將經濟、文化與社會所造成的影響納入考量，但也有不少受訪者持相反意見，認為不應該將酒駕與原住民身分連動在一起，甚至認為這可能反而形成一種刻板印象。

「那花東就交通不便。」(J1)

「又沒有其他的交通工具這樣，計程車也不會來。」(L3)

「這個是當地本來就公眾交通工具極為匱乏造成的，這個其實跟原住民沒有太大的關聯性。」(J3)

「跟他的族群的事沒有那麼緊密的，反而是經濟、文化的、社會的問題。」(J2)

「我不會用原住民族去講酒精使用，那是刻板印象。所以我不會去講說因為你是原住民族。我聽到辯護人講說原住

民，會覺得很不舒服啊。原住民使用酒精駕車，不是文化的關係，而是部落交通的關係。」(L2)

「但是好像某方面來看，就是一種歧視。」(J5)

除背景因素，受訪法官也多對文化抗辯適用與否提出看法。如有法官(J3)直言，酒駕不應該是除罪、減輕、免除其刑的範圍；也有法官(J2)認為無法否認酒駕與原住民的關聯，但考量酒駕還與經濟、社會等其他因素相關，故主張並非僅靠制定除罪化規定即可解決；又或者有法官(J4)認為檢討酒駕的刑罰是可以的，但在生活情況不具特殊性時，不應該將酒駕納入文化抗辯的考量範圍。

「我覺得這一塊也沒有特別去除罪或是減輕、免除其刑的必要。」(J3)

「你不能說跟原住民無關，但是它某程度上是已經牽動到原住民族在這個花蓮地區，或是整個臺灣地區的經濟、文化、社會的問題。它不是一個很單純我們設計一個除罪規定就可以解決的問題。」(J2)

「站在刑罰是不好的東西來講，我是贊成啦。就一般實務上而言，如果你主張這個，你沒有主張特別的。如果你生活區域也不是太誇張的地方，一般法官也不會管，不會特別在意……。」(J4)

綜整來看，各訪談意見的共通點在於，其皆承認酒駕牽涉社會、經濟、文化及資源分配等複雜背景因素。這不僅與對判決的觀察相一致，也與原住民族對酒精的理解及使用發生轉變的研究相呼應⁵⁶。此外，這些意見也與判決分析一致，認為既然酒駕形成並非

⁵⁶ 如傳統上酒代表豐收、作為與祖靈溝通的管道，自我節制並強化社群組織，具有文化上的意義，惟經歷日本及國民政府的殖民統治，使得部落生產方式產生

僅與原住民族文化相關，還涉及居住地區差異、大眾交通工具欠缺，乃至於經濟、文化與社會所造成的影響，甚至是警察對於不同族群的差別性執法，其與主張文化抗辯時有較高正當性的自然資源利用有所差異。正因如此，訪談資料與判決分析的共同傾向是認為，酒駕不應直接視為可阻卻違法而為法秩序認可的行為，不應制定個別除罪化規定。

然而，以上述共通點為基礎，關於文化抗辯適用的觀點則有差異，有認為酒駕完全沒有適用餘地者，也有允許特殊生活狀況下可適用者。不過，後者正因欠缺除罪化規定作為直接抗辯的基礎，故以表8的酒駕判決為例，其明顯採取先論述背景因素來證成酒駕與原住民族文化的關係，再據此主張文化抗辯的間接抗辯模式。由於此模式難為我國法院系統肯認，自然出現判決全被上訴審撤銷的結局。

2. 妨害投票類型

接著，少數涉及妨害投票案件也值得注意。在虛遷戶籍案件中，律師提出布農族遷居與遺產的傳統習慣進行抗辯，但因鑑定人表示「布農族亦無女子繼承必須先遷移戶籍之習慣」，使被告獲判有罪⁵⁷。在檳榔賄選案件中，判決同時考量阿美族互贈檳榔文化與檳榔經濟價值低，認其「尚不違背國民之法律感情與認知而未逾越

鉅變，並使得集體認同失落，而大幅改變對於酒精的理解及使用方式。參照：夏曉鵬，失神的酒：以酒為鑑初探原住民社會資本主義化過程，台灣社會研究季刊，77期，頁54（2010年）。

57 臺灣花蓮地方法院108年度原選訴字第5號刑事判決，被告主張：「當時是因為我母親說要分我一塊土地，當時家裡面的人說要把戶籍遷回來，才會過戶給我，要遷戶籍是因為布農族的慣例」。法院認為：「況縱依鑑定人○○○之陳述，布農族亦無女子繼承必須先遷移戶籍之習慣，其所陳稱之需將戶籍遷移，僅係其誤認為辦理土地贈與登記的行政流程上需贈與人與受贈人之戶籍在同一戶口內所致，故此等行政登記程序上的誤解，顯然與布農族之傳統習慣無涉，而無被告及辯護人所稱之原住民族傳統習慣存在。」

相當性範圍」，而肯定文化抗辯主張⁵⁸。即使未如前述直接提出部落習俗為文化抗辯者，如在選舉制度減刑案中，亦有法官認為現代選舉制度有別部落傳統，考量其對原住民傳統權力機制的文化衝擊，「在固票、拉票、拜票等行止間易逸脫法律明定禁止規範之誠命」而肯認文化抗辯適用並依刑法第59條減刑⁵⁹。

下開訪談資料也同樣提及發生於妨害投票罪的幽靈人口案，不同於前述判決是為繼承而遷徙戶籍，律師提及者是為結婚而遷戶籍。並且因考量相關文化證據不夠充分支撐該項主張，改以其他方式進行訴訟。

「依照他們部落的傳統，戶籍要遷回來，然後遷回來你才是這個家的，你要在這邊結婚，然後我們送出去我們祝福。那當然他這樣跟我講我第一個反應就是說，為什麼漢人的戶籍制度跟原住民族的結婚會有關聯。」、「雖然我知道可能有這樣的一個可能性，但是我沒有東西可以去用……我連我自己都沒有辦法整理一個很好的東西出來，我更不可能給法官。」(L3)

58 臺灣花蓮地方法院108年度原選訴字第8號刑事判決：「食用檳榔、互贈檳榔確為許多原住民部落居民之慣常行為，且檳榔價格甚低，最高價時1顆不超過10元，依社會通常觀念，並與前揭所述發放面紙、扇子等物相較，堪認其贈送價值尚不違背國民之法律感情與認知而未逾越相當性範圍，故有投票權人之投票意向是否確會因為取得1、2顆檳榔或香菸受影響，不無疑問，即難認上開物品客觀上確屬約定投票權人為投票權一定行使之對價。」

59 臺灣花蓮地方法院103年度選訴字第11號刑事判決：「當代民主國家基於憲法保障人民參政權所設計之『少數服從多數、票票等值』之選舉制度，雖為民主社會之主流價值觀，但該選舉制度本非原住民族部落所有，且與原住民族部落之傳統權力運作機制迥異，蓋原住民族之部落治理，原係以部落頭目、長老作為其族人間之宗教、政治上之領袖，頭目與長老之意見具有一定之約束力，從而，當作為主流價值觀之選舉制度沁入原住民族部落，除因國家與部落之間權力不平等而造成相當程度之文化、社會結構改變之衝擊外，原住民族投身參政使用主流價值觀之選舉制度時，或因他故習染惡質選舉之風氣，或囿於部落內族人彼此間緊密之連帶關係，以致難以嚴守選舉制度禁止投票行賄之規範，因而在固票、拉票、拜票等行止間易逸脫法律明定禁止規範之誠命。」

將上述資料結合殖民治理的角度來觀察時，可發現當文化抗辯主張所持多元文化內涵，被理解為未對現有體制產生衝擊時（如：不違背國民法律感情），有機會提高文化抗辯主張的規範效力。不過，除非是衝擊極小的狀況（如：檳榔價格甚低），否則以現代制度「異於傳統文化慣習」或「帶來文化衝擊」為由抗辯者，雖有法官願意對此予以減刑，但並不容易被維持（如：選舉制度減刑案即遭上級審撤銷）。事實上，此狀況與酒駕案件相似，當欠缺除罪化規定可援用來提出直接抗辯，故透過論述文化慣習與現行體制之衝突與犯行的關聯，採用間接抗辯的模式時，此作法目前尚難被法院所肯認。

3. 制度衝突類型

在酒駕與妨害投票等案件類型中，可觀察到當代原住民族面對經濟、社會與文化變遷，其傳統文化慣習因與現行體制衝突而成為犯罪。也可看到在此狀況下，為否定文化實踐行為的違法性與可罰性，文化抗辯適用與否成為法庭活動的爭執重點。事實上，在這兩個類型外，有不少已具體產生制度衝突的原住民族刑事案件。即使司法實務對這些案件的認事用法通常不會直接論及原基法，被告也少有主張犯行肇因於文化慣習，而非屬傳統定義下的文化抗辯類型。但這些案件中的被告主張常與其傳統文化或習慣有關，而有實質上被理解為一種文化抗辯的可能。

第一個例子是一則源自亞泥利益分享機制說明會的公然侮辱判決⁶⁰。該案被告雖然並未主張妨害名譽行為是出自文化慣習，而非

60 臺灣花蓮地方法院111年度原易字第75號刑事判決：「本案說明會之議程中，並無表決之程序，有會議程序表照片附卷可稽，且證人○○○於本院審理時復證稱：那個時候是在做說明會，我們沒有講那個時候要表決，我們只是要做說明讓族人了解我們今天所要講的是什麼，我們當下都很恍然，為什麼主席他就可以自己就代表他自己當場就說我們要表決，告訴人開會前也沒有跟我說今天要表決，每個幹部都嚇一跳等語，核與證人○○○於本院審理時證稱：我開會之

屬傳統定義下的文化抗辯類型。惟自判決文字來看，被告主張其公然侮辱的行為背景，是被害人主持基於當代法秩序進行的會議時，違反具有文化概念意涵的太魯閣族傳統規範GAYA，雙方因而發生衝突。由這樣的背景來觀察，被告行為可以放在傳統規範回應當代秩序的文化衝突被解讀。被告提出「他做這動作，完全違反我們太魯閣族的GAYA文化，沒有按照祖制來做」的主張，即是以傳統規範主張其行為並無不法或無可罰性，也可以被理解為具有文化抗辯的性質。

第二個例子則出於受訪律師的意見，律師將此案件類型定性為「公民不服從」。包括：清水發電廠說明會中抗議行動所致毀損罪與強制罪、臺東都歷垃圾場抗爭引發的妨害公務罪等，均可以歸類於此類型。在此類案件之中，受訪律師認為原住民被告的犯罪行為是在傳統規範與現代制度的衝突之中，基於捍衛文化與傳統慣習之動機而生。誠然，這並非典型文化抗辯的形式，但以行為與傳統文化的關聯作為立論基礎，實質上也有被理解為文化抗辯的空間。

「我把它稱為『原住民的公民不服從』案件，為了捍衛文化慣習而有抗爭行為，例如之前有一個是都歷垃圾場，族人去抗議，就出現妨害公務的行為。」(L5)

「族人大批的就移動到會場的前方，然後就是做抗議的行為啦。……因為他就有去踢到那個會場的椅子，然後他後來就被那個當天有去的廠商的代表就告說他毀損了椅子。後來就那一波他們這樣抗議之後，就主席出來主持啊，總之

前不知道會有表決這種東西，我到主席台前面就是要跟告訴人說你程序不當，你並沒有告訴我們今天要做表決，他做這動作，完全違反我們太魯閣族的GAYA文化，沒有按照祖制來做等語，可證本案說明會過程中，原無表決之程序，告訴人突如其來請部落族人舉手表決，造成突襲，除被告外，亦有其他族人至主席台前理論。」

就是場面有點混亂，反正最後說明會就終止了。所以廠商就一起告他強制罪，讓我們會議開不成。」(L4)

總結來說，縱使上述抗辯並沒有被廣泛運用或承認，也因欠缺除罪化規定且與原基法規定無涉，難以連結至阻卻違法的效果，非屬於典型的文化抗辯。但透過這些例子，或許可以想像在普遍與文化慣習直接連結的傳統自然資源利用外，包括已有少量判決的酒駕及妨害投票案件在內，這些淵源於殖民制度、外來文化與原住民族文化慣習間衝突的案例，有無可能以更多元的角度詮釋文化抗辯，進而擴大其適用範疇，可說是文化抗辯理論深具探討價值的面向。

4. 儀式評價類型

刑事程序對案件的重要性不亞於刑事實體法的論罪科刑，其中也不乏可能與原住民族文化連結者，惟此種案例並不容易形諸於判決。舉例來說，曾有受訪法官(J4)提及在妨害性自主案件，被告認為業已經殺豬儀式並與對方達成共識，因而對該案件仍遭刑事訴追感到不解。這項案例值得注意之處在於，被告以該項儀式在特定原住民族文化下的和解意義為基礎，認為紛爭、責任追究既已終結，則國家的刑事訴追亦應終結。這個作法，雖然不是強調傳統文化與犯行之間的關係、訴求無罪或減刑的文化抗辯典型模式，但從儀式的傳統文化意涵出發，認為對於犯行的追究應予終結，則可以將之歸納為與刑事程序相關的文化抗辯。然而，目前此類儀式在刑事程序中應如何受到評價，其文化意涵能否轉化為刑事程序相似概念（如：撤回告訴）等，並沒有受到完整的討論，而未來應對於文化抗辯與刑事程序之間的關係予以釐清。

「假設……被侵犯、不禮貌之類的，然後對方必須要殺豬，然後宴請客人……賠罪的一個動作，然後讓這個事情過去。」、「有主張是說，都已經有和解，然後有殺豬了，然

後那時候有請宴客了，為什麼還是要告我，當初不是這樣約定好了？」(J4)

另一則案例來自於受訪律師(L2)，表示部落促成和解的方式並非透過金錢賠償，而是採「一物還以一物」。該案件源於衝突而殺害對方犬隻，之後和解條件乃是賠償對方同種類犬隻，並藉此達成共識。

「有跟當事人和解，和解的作法很奇妙，部落的作法就是賠他一隻比特犬。」(L2)

現實上，此種訴訟外的儀式，確實可能被轉化進入刑事程序體制，成為民事和解條件一部而對於告訴乃論之罪撤告。相較之下，上述殺豬和解案例，面對現行法限制而有其困難（如妨害性自主案件為非告訴乃論之罪，無法撤告）。不過，考量文化儀式對於刑事程序被告及被害人的積極意義，即使無法如傳統文化中被理解為追訴的終結，但在現行法之中，仍可能轉化為影響量刑的文化抗辯主張，供法官科刑時考量。總結來說，傳統儀式的文化意義如何在刑事程序受到評價，目前尚未被詳加討論，此亦為文化抗辯理論發展時不容忽視的面向。

5. 原住民身分類型

除面臨經濟、社會變遷，以及文化與制度的衝突外，原住民身分認定目前也受到挑戰。而從文化抗辯的定義來看，身分認定問題自然會與文化抗辯的適用產生連動。以下開訪談為例，當行為人的法定身分不符合原住民身分法的原住民定義，但主觀上認為自己是原住民並從小接受此等文化薰陶者，能否主張文化抗辯（如J4）？或者，當非原住民身分被告與原住民被告有行為分擔而為共同正犯時，非原住民被告能否主張文化抗辯（如J2）？均為值得探索的問題。

「從小被那個原住民教長大，長大之後才發現……原來我是漢人，那難道他們基於這個，不能夠主張（槍砲條例）20條嗎？不能去採取嗎？」（J4）

「問題就是說，今天我一個跟原住民生活在一起那麼久的一個……也沒有很久，大概三、五年的這樣的漢人，那我把槍給他，我賣給他好了，我給他使用，那構成犯罪嗎？」、「比如說我今天原住民持槍然後交給漢人之後呢？那當然我們會說漢人……在某種程度上他不能持槍嘛，因為他基於……就是那個他不是那個我們除罪規定的那個保護的對象，但是某程度上呢，我說一個案件比較特別，就是他幫原住民寄藏，那這種狀況之下，你真的會說，完全不考慮在文化上的因素去處理這個問題嗎？也很難。」（J2）

受限於原住民身分法的限制，原住民是以血緣認定作為基礎，這導致不具血緣者即使長期浸淫原住民族文化或身處原住民族生活中，既不會在原住民專庭（股）審理，也無從適用除罪化規定，更不易主張文化抗辯。詳言之，由於現行法制之身分認定具排他性，除了不具有原住民血緣者，即便是原住民與非原住民所生子女，具有原住民血緣，由於未從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，也無法認定為原住民⁶¹。然而，原住民身分法的認定是否要與除罪化規定所適用的對象劃上等號，或有無其他法解釋的可能，都容有討論空間。2022年4月1日，憲法法庭111年憲判字第4號判決已經就此身分法制的爭議作成判決，要求立法部門應於宣示日2年內對於原住民身分法進行修法，這也勢必影響未來文化抗辯得否及如何適用於原住民身分案件類型。

61 原住民身分法第3條第1項：「父或母為原住民，且符合下列各款規定之一者，取得原住民身分：一、取用父或母所屬原住民族之傳統名字。二、取用漢人姓名並以原住民族文字並列父或母所屬原住民族之傳統名字。三、從具原住民身分之父或母之姓。」

三、適用範疇實證結果的規範意義

以上對2004年至2023年花蓮地院曾論及文化抗辯之案件的分析，呈現出文化抗辯範疇的當代面貌與未來可能的發展重點。對照下圖2，可簡單從「適用範疇」及其對應「文化想像」、被告所採「抗辯模式」與法官對應刑法體系所採「判決方式」等四個面向，來統整觀察結果。



圖2 適用範疇實證結果

資料來源：自行繪製。

首先，文化抗辯適用案件類型最侷限的是「A.立法除罪範疇」，以各法規中的除罪化規定為界限。故此範疇對應的文化想像中，只有立法者於各除罪化規定中承認的行為態樣，屬於法秩序認可的文化實踐。因此，抗辯模式是對符合除罪化要件之行為，直接援引該規定主張文化抗辯之適用。法院則多肯認此抗辯，適用刑法第21條「依法令行為」，在違法性階層中阻卻該行為違法性。

接著，將適用案件類型擴及於欠缺除罪化規定適用之自然資源利用的，是「B.基本法規定範疇」，以同屬明文規範但性質有爭議的原基法第19條為適用界限。此範疇對應的文化想像中，不限於各除罪化規定具體指涉者，凡符合原基法第19條要件的自然資源利用，皆屬原住民族文化實踐。抗辯模式則依對原基法規定的性質認定而有別，認為該規定屬除罪化規定者，與A範疇抗辯模式相同，直接援引該規定來主張文化抗辯（模式一）；認為該規定非屬除罪化規定者，則是先從原基法規範意旨來論述犯行與原住民族文化的關聯，再據此提出間接抗辯（模式二）。目前，上級審法院與多數一審判決傾向不將原基法規定定性為除罪化規定，並據此否定文化抗辯的成立。然而，可見到法院否定文化抗辯的同時，迂迴地從主觀構成要件或責任階層來論述行為不成罪的判決方式。

最後，有別於前二者，適用案件類型最廣的是「C.非明文範疇」，其對應的文化想像不限於刻板印象的自然資源利用，其他基於傳統文化慣習而與現行制度有別者或因文化衝擊而生者，都可理解為文化實踐。但因範圍較廣且欠缺對應的除罪化規定，此類型案件多半透過說明犯罪行為與文化衝突間的關係來間接提出抗辯，這些文化抗辯則多為法院否決。不過，在此脈絡下，同樣可看到法院透過阻卻構成要件或罪責等解釋路徑，判決不成立文化抗辯的行為無罪或減刑的案例。

綜上所述，如圖2所示，目前透過一審判決與上級審審查，法院肯認文化抗辯的案件類型被限定於A範疇中，亦即僅存在可適用的除罪化規定時，才有機會適用文化抗辯並根據「依法令行為」阻卻違法。以下嘗試對此經驗性事實，賦予其規範意義。

（一）案件適用範疇的規範意義：規則與原則之分談起

根據上開實證分析描述的法現象，可發現法官會區分案件有無除罪化規定的適用，僅設有除罪化規定之案件類型得適用文化抗辯，反之則否。而從此「立法除罪範疇限定現象」，以及「玫瑰石私採案」（參、二、（二）、3）中一、二審法院根據對原基法第19條性質的認知來決定是否適用文化抗辯的狀況來看⁶²，可發現法院依循立法實證性認事用法與文化抗辯適用範疇間的關聯。

對此，若著眼於文化抗辯的提出模式，將援引除罪化規定提出的「直接抗辯」，以及透過原基法規定或文化衝突相關事證，先論述犯罪行為與文化間關聯再提出的「間接抗辯」，視為運用法規範證立特定主張的法律論證過程時，這些抗辯模式的差異，及其所構成的理由在結構上的差異，或可成為對上述法現象賦予規範意涵的切入點。對此，以下先嘗試從規範理論對「規則」（rules）與「原則」（principles）的區分切入⁶³，對法現象提出規範性詮釋。

鑑於本文旨趣，在此僅簡述規則與原則的區分⁶⁴。原則是在表達某種價值或目的，且作為一種「最適化要求」（optimization

62 一審接受文化抗辯的邏輯：「原基法第19條為除罪化規定，故可適用該規定，認為採集行為阻卻違法」；二審拒絕文化抗辯的邏輯：「原基法第19條非除罪化規定，故無法阻卻違法」。

63 二概念內涵與區分，見：顏厥安，法與實踐理性，頁62-69（1998年）；王鵬翔，規則、原則與法律說理，月旦法學教室，53期，頁75-78（2007年）。

64 概念詳細內容見本文參照文獻：RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 14-45（1978）；王鵬翔，論基本權的規範結構，臺大法學論叢，34卷2期，頁1-28（2005年）；顏厥安，規則、理性與法治，臺大法學論叢，31卷2期，頁15-17（2002年）。

requirement)，其要求價值與目的在個案中應盡可能以最高的程度被實現。在此意義上，原則可在個案中作為支持某判決結果或法律主張的理由。不過，由於在個案適用中可能存在數個彼此相衝突的原則，故其僅能作為初步性的理由（*prima facie reason*）。至於最終該個案中何原則具有實現優先性，則須透過對彼此重要性的衡量來決定，亦即原則的重要性面向（dimension of weight or importance）。

規則異於原則，其作為只能被適用或不能被適用的規範，具有「全有或全無」的特性（all-or-nothing character），故當規則被適用於個案中且其要件被滿足時，無需透過衡量即會產生確定且應被接受的法律效果。換言之，規則在法律論證中作為一種決定性理由（decisive reason）。同時，由於適用規則時可排除對背後各初步理由進行衡量，故其也作為排他性理由（exclusionary reason）而存在。至於這些性質，則源於其出自立法者等權威制定時，使之成為可獨立於內容的理由。

依循上開架構來詮釋實證現象時，考量原基法呼應憲法增修條文原住民條款的多元文化主張，與以原住民族文化權利主張作為存立基礎來開展其權利系譜的內涵⁶⁵，以及其對特定條件下原住民族自然資源採集權保障的訴求形式，應可將其理解為針對自然資源採集，揭示「多元文化」此一原則的規範。與其類似，憲法增修條文原住民條款揭示更廣泛的權利內涵，以保障多元文化之原則。話雖如此，無論是主張適用原基法，或者論述個案存在文化衝突後操作違法性的法益衡量，當透過這些間接抗辯模式來主張案件適用文化抗辯而阻卻違法時，判決分析顯示法院多持否定立場。此現象代表的意義，或許是當法院在非屬立法除罪範疇的個案類型中進行原則

65 蔡志偉（Awi Mona），民族法主體之建立：臺灣原住民族自治之視角，臺灣原住民族法學，1卷1期，頁78-85（2016年）。

衡量時，即令多元文化已有規範依據可作為初步理由，但面對各種刑法保護法益，即顯現重要性相對較低的評價，亦即多元文化原則個案重要性往往低於法益保護原則。或者，即使承認原住民族文化作為保護法益，當該文化實踐侵害財產、交通往來安全或投票正確性等法益時，法官可能難以論證其與非原住民者侵害這些法益的差別何在，亦即難以論證文化法益的優先性。

若上述現況為真，則唯有透過立法權威制定毋須個案衡量多元文化原則重要性，僅需符合特定要件即可產生適用文化抗辯結論的規則，才可能使原住民族侵害法益的文化實踐行為有阻卻違法的可能。事實上，文化抗辯適用案件類型侷限在立法除罪範疇的現況，可能正符合這樣的詮釋。詳言之，雖然多元文化在法院實際運作下作為較弱的原則，但法官確實呈現出在立法制定除罪化規定的案件類型中，願意適用文化抗辯並基於阻卻違法而採取無罪路徑的行為傾向。而由法官並非透過超法規阻卻違法事由的操作，而是將各除罪化規定作為「依法令行為」成立依據的論述方式來看，其並非透過原則衡量的方式，而是直接適用由立法權威制定而作為「規則」的除罪化規定，並在個案滿足該「規則」之要件時，據以適用阻卻違法與無罪的效果。

綜上所述，本文認為文化抗辯適用的「立法除罪範疇限定現象」，其隱含的規範意義是：多元文化相較於法益保護，在刑法違法性衡量中可能處於較弱的位置。不過，值得注意的是，訪談資料曾指出法官提及除罪化規定帶來「卷宗暗示」、「心裡有底」等影響，而將文化抗辯適用聚焦在立法除罪範疇。呈現出法官對立法實證性的依循與文化抗辯適用有所關聯的現象。本文認為這可能揭示另一個規範意義：除罪化規定作為「規則」，透過立法權威形成獨立於內容之理由的影響性可能存在。亦即，除罪化規定出自立法者制定一事，可能對文化抗辯被適用具有較高影響力。下段（二）即嘗試分析此影響性可能成因與理論意義。

（二）立法與司法複合機制形塑的文化趨同

上段（一）已回答第貳部分所提的問題一，針對法官依循立法實證性，而以除罪化規定存否為基準，決定是否適用文化抗辯的法現象，指出其可能的規範意義。接著，作為本文第參部分對問題三的回應，以下將嘗試從文化趨同的角度來理論化「立法除罪範疇限定現象」，並結合訪談資料說明除罪化規定對文化抗辯適用具較高影響力的可能理由。

在第貳部分關於文化抗辯研究從理論到實踐的轉向中，提到「文化抗辯基於抗辯理由與主流社會預設價值暗合而得以獲得有利判決，卻也因此限制文化抗辯適用範圍」的「文化趨同」。從立法承認特定行為為文化實踐並制定除罪化規定，卻反而使法官將適用案件類型限定於立法除罪範疇以觀，似乎出現可呼應他國理論的狀況。但從實踐層面來看，臺灣與國外文化抗辯透過司法實踐形成文化趨同的發展並不相同：如下開受訪法官意見所呈現的，作為繼受歐陸法系為主的刑事司法系統，法官依循立法實證性適用文化抗辯，以及適用的案件類型趨同於立法制定之除罪化規定，顯現在司法實踐外，規範的立法也扮演形塑臺灣文化抗辯的重要機制。

「拿到卷的時候，卷皮上有案由。如果我們沒有專業證照受訓，那就變成法官他個人曾經在求學及執業歷程這些資訊，例如他參加研討會或在法官學院上課，或以前司訓所有上課，那大概會知道這些訊息。說野生動物保育法，或者是說槍砲、森林。大概看到這三個時候，法官會有些感覺，會有這方面類型的抗辯。如果今天是竊盜或者殺人，就好像沒有關係。雖然也是不一定。」(J1)

既然這個來自於立法明文而形諸成文法典的文化趨同現象，是透過司法實踐與規範的立法交織而成，以下嘗試將前段透過規則與原則概念詮釋的規範意義，放入司法與立法交織作用的框架中，為

依立法實證性認事用法及判決趨同除罪化規定的現象賦予理論意義。對此，本文從除罪化規定的「規範指示作用」談起。當立法者制定除罪化規定時，由於其可免於衡量就直接適用文化抗辯，故可清楚指出被立法權威承認多元文化高於法益保護原則的行為態樣。亦即，透過成文法典標示出有文化抗辯適用可能的案件類型為何。而當法官要做出某案件類型是否可能適用文化抗辯的肯否二元選擇時，法官在依法審判的要求下，可能受該除罪化規定的指示引導，產生依立法決定進行選擇，使文化抗辯適用限定於立法除罪範疇的趨同現象。換言之，透過立法部門制定法規範並劃定對原住民族的文化想像，法官可能受引導而於法規範中「戴著腳鐐跳舞」，透過程序運作與法律解釋，被引導而提出對審理個案的文化想像及法律評價。然而，此解釋必然被提問：法官為何會受到除罪化規定所引導？

就此問題，或可從除罪化規定由立法權威制定而可作為排他性理由的角度談起：對法官來說，受作為權威的除罪化規定指示，可符合「效率」及「正確性」的論據⁶⁶，而此二者也正是刑事程序最基本的要求。不過，此二論據與指引機制得以成立，並非僅依靠規則本身，尚須依靠與其他司法制度的配合。

首先，從目前除罪化規定與司法體制交織作用來看，「效率」考量可能是法官傾向接受立法權威而受作為「規則」的除罪化規定引導的原因。一方面，適用規則可節省進行原則衡量的成本。如以下訪談資料（J4）提到刑事司法負擔的辦案成本考量，包括支撐文化抗辯的文化證據調查因文化獨特性而相對比一般案件更耗費時間，或人證表徵特定文化概念在法庭運用的考量不容易等。從降低成本、追求效率的角度來說，法官會傾向在已有前例可循的立法除罪範疇中適用文化抗辯，而律師與當事人也意識到法官傾向，而被

66 二者作為規則成為排他性理由的論據，見：王鵬翔（註63），頁80。

引導在此範疇中提出抗辯，透過法庭活動將文化抗辯適用限於立法除罪範疇中。

「例如是不是森林法的傳統領域……也會問原住民身分認定，然後還有槍的部分，殺傷力到什麼程度，與自製獵槍的範圍，會拿來參考這樣子。大部分，除非是第一個案件，我們都會先參考之前的案例，之前的案例說要函什麼東西，我們就會去函。」(J4)

另一方面，從適用規則可免於不確定性（達成安定性）來看，除文化抗辯牽涉法庭活動的不確定性因素外，如下開受訪法官與律師看法，相較於法官適用原基法或描述文化衝突等論理來提出（間接）文化抗辯時，必須說理、衡量與面對上級審可能的撤銷判決，將判斷交給立法權威而適用屬於「規則」的除罪化規定，將適用範疇限定在立法除罪範疇，可達到免於不確定性的要求。這些都可能引導法官，使適用範疇安定化而形成文化趨同。

「這一塊沒有調查清楚，其實你這判決就很容易被二審撤銷了。」(J3)

「那你覺得為什麼他不想處理？原因是因為太麻煩？太麻煩了，而且會有被發回的風險。」(L2)

接著，從「正確性」作為立法權威論據的角度來說，若法官預設具有民意基礎或資訊較完整的立法者判斷相較於自己的判斷來得正確，認知除罪化規定代表正確衡量結果，也會引導其傾向適用該規則。除了判決分析呈現上級審對立法除罪範疇內外案件適用文化抗辯時的差異對待現象，可能強化法官對除罪化規定正確性的預設。以下訪談中提到司法部門的固定函文模式（如：對於特定文化證據的調查例稿）、上級審的監督（如：以未調查除罪化規定所涉證據作為上訴三審事由），以及圍繞而生的知識體系（如：司法官

學院及法官學院相關課程內容)，都可能是引導法官依循立法實證性適用法律，認知除罪化規定較具正確性的原因。

「大概都是在森林法啦，或是槍砲、野生動物保育法等等
的，大概目前其實就原住民來說，我覺得整個辦理下來，
我覺得比較值得同情的大概也是這幾種類型，其他我倒是
覺得還好啦。」(J3)

「例如森林法，這個可能會去函文說，這個到底是原住民的
這個區域啊，傳統領域是哪些啊，到底有沒有在這個範圍
內啊……對，會函這樣子。然後其他以前有聽過就會問說
原住民身分的認定是怎麼認定這樣子。」(J4)

Jean E. Jackson曾對形塑文化抗辯的「原住民性」(degree of indigeneity)這種以自然化想像建構原住民性的理解提出解釋，認為這與原住民族被主流社會理解的範疇有關，而此一來自社會的集體建構也將影響權利實踐的樣態⁶⁷。若將此解釋中的主流社會，置換為代表臺灣民意的立法部門及形塑法官思維的司法訓練單位，或許我們也可從訪談中有法官認知文化抗辯僅侷限在某些案件類型，認為多數族群案件與一般案件無異的想像中，觀察到前述機制產生類似影響。亦即，除罪化規定不只透過規範效力引導法官，也可能配合司法制度建構法官對族群文化的認知與想像。如此一來，即便法官對原住民性存在不同於立法者的認知，但受限於由立法與司法複合形塑文化抗辯的機制，即使不受規範引導，也只能在此機制可接受的範圍內嘗試透過量刑路徑等加以調節。

綜上所述，本文嘗試分析法官可能為何依循立法實證性而適用除罪化規定，受這些規定引導形成文化想像與適用文化抗辯，同時

67 JEAN E. JACKSON, MANAGING MULTICULTURALISM: INDIGENEITY AND THE STRUGGLE FOR RIGHTS IN COLOMBIA 22-24 (2019).

產生適用範疇被侷限於立法除罪範疇的趨同現象，描繪出臺灣文化抗辯形塑機制的樣貌。誠然，有受訪律師（L3）曾表示：「我覺得文化抗辯就是可能是原住民族……在自己的生活，或者是一些環境、一些日常生活的實踐」，指出文化與生活的關係，並對於原住民族文化性進行較為廣義的詮釋。或者，也有受訪法官（J1）表達：「那其實有些文化抗辯也是我們目前不知道的」，而對文化抗辯保持比較開放與靈活的空間。然而，實證觀察顯示，在立法與司法複合機制運作下，法官自由適用文化抗辯的空間相當有限。若以本文區分的五種非明文範疇案件類型為例，其皆呈現出文化衝突不僅限於傳統自然資源利用，也可能來自外來政權殖民統治導致的社會經濟地位剝奪與文化流失，乃至於原住民族法制衝突導致的矛盾。這些均涉及當代文化內涵的不同詮釋與挑戰當前文化抗辯適用範疇的可能。但從實證現象來看，面對狹隘的適用範疇，其皆未為司法系統所承認。

肆、文化抗辯要件理解的實證考察：以案件事實為中心

第參部分說明法院適用文化抗辯的案件類型，並指出其侷限於立法除罪範疇的現象。以圖2來說，第參部分聚焦於A與B、C間的關係，指出A以除罪化規定為界限，文化抗辯適用案件類型被限定於A範疇內的現象。在此，第肆部分將聚焦屬於A範疇的案件類型，也就是在A的內部，觀察當個案符合除罪化要件T則可阻卻違法而獲得無罪判決時，法官如何解釋適用T，藉此釐清其會將何類型案件事實理解為原住民族文化實踐，進而描繪其文化想像。以下依序以2001年至2004年立法制定除罪化規定的森林產物採取、野生動物獵捕與槍枝持有等行為為觀察對象，透過修法前後文化抗辯的

適用情況與適用抗辯時賦予法律效果之路徑，嘗試剖析法官對各行為類型的文化想像及其與立法間的關係。

一、森林產物採取的文化想像：以森林法第15條第4項理解為中心

根據森林法第15條第4項規定，若原住民採取森林產物行為，是在原住民族傳統領域土地內依其生活慣俗需要所為者，即屬得阻卻違法之依法令行為。換言之，根據法官對其成立要件的理解，即可描繪法官認知之下得為文化實踐的森林產物採取行為樣貌，亦即其文化想像。本文以存在公開資料的2000年至2023年間，構成森林法第50條竊取森林產物罪與第52條加重竊取森林產物罪的107件案件為對象，嘗試分析法官如何解釋森林法的除罪化規定內涵，並與訪談資料參照比較，藉此釐清法官對森林產物採取行為之文化想像。

上述森林法的除罪化規定是在2004年1月修法增訂，原僅處理國有林區內當地居民採取習慣之問題，後經政黨協商將原住民族作為適用對象，表示對其傳統的尊重，予以增訂並三讀通過⁶⁸。此

68 行政院2002年提出森林法修正草案時，並未將除罪化規定制定於森林法第15條立法院修法資料，而是在立法審議時經政黨協商通過。當時擬增訂條文為「國有林區內當地居民有採取雜草、枯枝、落葉之地方習慣者，得由林區管理經營機關限定區域、時期及採取種類，發給採取證」，嗣後經立法院經濟暨能源委員會審查時屏棄原提案。後經政黨協商，才有現行規定於森林法第15條第4項除罪化規定。立法紀錄參照：立法院公報，91卷33期3229號上冊，頁11-12（2002年），行政院提具條文：立法院第5屆第1會期第7次會議議案關係文書，院總第932號政府提案第8467號，頁1-7（2002年）；立法紀錄參照：立法院公報，92卷34期3308號三冊，頁314（2003年），審查報告條文：立法院第5屆第3會期第15次會議議案關係文書，院總第917號委員提案第4385號之1，頁677-681（2003年）。據參與修法之前林務局局長李桃生說法，此規定係源自林務局早年立法計畫，原計畫條文為「森林位於原住民世居領域者，許可原住民依其傳統採取森林產物，其採取之區域、種類、時期、繳費及其他應遵行事項之管理規則，由中央主管機關定之」。參照：李桃生，原住民族利用森林資源權利論——回顧與展望，台灣林業，46卷2期，頁45-47（2020年）。

後，2019年7月修法增訂的「原住民族依生活慣俗採取森林產物規則」（下稱：採取規則）將森林法第15條第4項規定明確化，明文規定得採取與不得採取的森林產物，以及編具採取森林產物計畫提案書提案的機制。

在此，先鳥瞰2004年1月除罪化規定修法後（下稱：修法後）的概況，作為從實證資料分析法官文化想像的素材。如表10所示，在107件案件中曾出現文化抗辯主張與論述者僅佔20.56%的22件。此外，從法官對這些案件的判決來看，並不存在因適用除罪化規定諭知無罪的判決，僅有單純諭知有罪與採量刑路徑兩種判決類型。正因如此，當試圖比較2004年修法前後法官對適用文化抗辯之案件的處理方式時，表11呈現出法官未因除罪化規定而從量刑路徑轉向無罪路徑的現象。相反地，2004年修法前後當法官肯定森林採取具文化意涵時，都僅選擇透過量刑路徑處理。

表10 修法後竊取森林產物論及文化抗辯之案件判決結果

判決結果	案件數(%)
有罪	14 (63.64)
量刑路徑	8 (36.36)
總計	22

資料來源：作者自製。

表11 修法前後竊取森林產物適用文化抗辯判決結果比較

判決結果	案件數	
	修法前	修法後
無罪路徑	0 (0%)	0 (0%)
量刑路徑	8 (100%)	8 (100%)
總計	8	8

資料來源：作者自製。

對此現象，推論上有兩點須注意：第一，不能僅因不存在使用無罪路徑的判決，就推論現實上不存在依生活慣俗的產物採取行為；第二，不能僅因修法前後未出現路徑轉向，就推論法官對產物採取的文化想像並未改變。詳言之，即使法官肯認文化抗辯後選擇的應對路徑不變，仍須分析法官修法前後對具文化實踐性質的森林採取理解有無改變，才能判斷其文化想像有無變化。據此，以下即從釐清修法前後法官文化想像的變或不變談起。

首先將目光放在修法後法官對森林採取的文化想像。要釐清此點，即須比較法官「適用文化抗辯且採量刑路徑」與「不適用而諭知有罪」的案件類型。詳言之，在法官認定森林採取行為與生活慣俗相關，故適用文化抗辯並將採取的文化面向納入量刑考量時，究竟何種行為類型被理解為實現原住民族文化而適用量刑路徑，有進一步探問的必要。

對此，由於從法院對除罪化規定的適用觀之，「採取對象（產物類型）」與「採取目的」是判決描述犯罪事實的主要面向，故本文即由此切入。從下表12可知，修法後無論是有罪判決或量刑路徑判決，犯罪事實都以牛樟芝、牛樟殘材與紅檜樹瘤為主要採取對象，產物類型並無太大差異。對此，一方面可推論採取對象可能並非影響法官是否於個案適用文化抗辯的因素，另一方面可思考：對應產物類型的特質（如牛樟芝、金線蓮作為藥品；樹瘤與蘭花可能作為裝飾），採取這些類型之目的，或許是與文化抗辯適用與否相關的因素。

表12 修法後竊取森林產物適用文化抗辯案件採取對象

判決結果	採取對象	案件數	2019年採取規則制定	
			制定前	制定後
有罪	牛樟芝、牛樟殘材	9	3	6
	紅檜樹瘤	5	2	3
量刑路徑	牛樟芝、牛樟殘材	6	5	1
	紅檜樹瘤	1	1	0
	四季蘭	1	1	0
	金線蓮	2	2	0

資料來源：作者自製。

基於上述猜想，本文在下表13與14中區分有罪與量刑路徑兩種判決，釐清法官選擇適用與不適用文化抗辯的犯罪事實，分別基於何種採取目的。首先，在法官適用文化抗辯而將文化因素納入量刑考量的案件中，可發現犯罪行為普遍是出於「醫療（自己或家人）」與「自家觀賞」等目的。若結合表12關於採取對象多具藥物或飾品性質的觀察，或可描繪出法官對森林採取的文化想像：基於醫療目的採取具藥物性質產物、基於觀賞目的採取產物為裝飾物。相對地，在法官否定文化抗辯適用而論知有罪的案件中，採取行為絕大多數是出於「獲取利益」之目的。特別是，若注意到唯一非出於獲利目的（基於醫療目的）而被判有罪者，實係肇因於2019年採取規則第6條第2項將牛樟芝列為不區分採取目的，原則上一律禁止採取之類型，才導致無法適用除罪化規定。或可推論出於獲取利益之森林採取，絕非可納入法官文化想像的類型。

表13 修法後竊取森林產物適用文化抗辯案件採取目的
(量刑路徑判決)

行為目的	案件數	2019年採取規則制定	
		制定前	制定後
醫療	6	5	1
自家觀賞	2	2	0
總計	8	7	1

資料來源：作者自製。

表14 修法後竊取森林產物適用文化抗辯案件採取目的
(有罪判決)

行為目的	案件數	2019年採取規則制定	
		制定前	制定後
獲取利益	13	7	6
醫療	1	0	1
總計	14	7	7

資料來源：作者自製。

上開觀察若搭配訪談資料，並將不存在文化抗辯相關論述的案件合併觀察，將會更清楚。如有法官（J4）在訪談中提到，關於除罪化規定的適用，會聚焦在被告目的為建築、雕刻、裝飾（非營利自用類型）或販賣。更有受訪法官提到案件事實涉及重量極重的木材時，不諱言地說道「這個東西分明就是拿來賣」，並且以此作為得否適用除罪化規定的判準。呈現出獲利目的與除罪化規定適用與否的關聯。再者，若排除採取規則的制定對判決結果的影響，以該規則制定前的案件為範圍，在被告未主張或法官未適用文化抗辯的74個案件中，有69個案件的森林採取是出於「獲取利益」之目的。當出於獲利目的之森林採取若非自始被參與者否定文化抗辯的可

能，就是提出文化抗辯後被否決，或可推論該行為未被涵括於法官文化想像中。

「這個檜木他們是拿來觀賞，是什麼關係？是拿來蓋房子、拿來雕刻、單純擺飾還是販賣？」(J4)

確認修法後是以「醫療目的採取具藥效產物」與「觀賞目的採取產物」作為法官對森林採取的文化想像後，接著目光轉向修法前法官採量刑路徑判決之案件。下表15中可供觀察樣本雖不多，但同樣從「採取對象」及「採取目的」觀察，可發現此階段被適用文化抗辯的犯罪事實略有不同。首先，採取對象並無修法後主流的牛樟芝、牛樟殘材與紅檜樹瘤，而是以箭竹筍、牛奶榕等可食用產物為主。此外，修法前8個被接受適用文化抗辯的案件中，其採取目的全部皆為「食用」。換言之，若要描繪此階段法官對森林採取的文化想像，可能偏向以食用產物作為傳統文化的實踐樣貌。

表15 修法前竊取森林產物適用文化抗辯案件採取對象

採取對象	案件數
箭竹筍	4
牛奶榕	2
金線蓮	2

資料來源：作者自製。

至此，總結以上觀察，有兩點值得說明⁶⁹。第一，上開觀察顯示在修法前後法官對原住民族森林採取之文化想像，具有從「食

⁶⁹ 非本文主題但相關的現象是在修法後的107個案件中，並不存在以食用為目的之森林採取。在難以想像現實上此種行為不存在的預設下，一個猜想是此類型採取未進入審判程序。詳言之，林務局相關研究報告曾指出，在2008年至2017年的不起訴處分書的分析中，不起訴主要原因除「行為不該當主觀構成要件」及「證據不足以證明犯罪嫌疑」外，即是「原住民被告森林採取出於生活慣俗」，陳湘繁（計畫主持人），盜伐歷史資料統計分析項目應用於竊取森林主副產物犯罪問題與防治研究計畫，委託研究計畫期末報告，頁18（2021年）。若

用」擴及「醫療、觀賞」的現象，同時劃出「獲利行為」無法納入文化想像的清楚界限。在此，值得注意在2019年採取規則第3條對「生活慣俗」提出清楚定義時，包括「非營利」與「生活需要：食、衣、住、行、育、樂、醫藥行為」等要素，都與法院判決呈現的文化想像重疊。換言之，雖然目前資訊不足以推論2004年除罪化規定立法時，作為要件的「生活慣俗」是否與修法前以食用為核心的法院文化想像一致，但2019年採取規則對生活慣俗的描述，確實與2004年至2019年間法院文化想像重合。如此一來，在森林採取的部分可觀察立法部門與法官文化想像趨於一致的現象。

第二，從2004年至2019年的發展來看，可發現在採取規則明文承認醫療與觀賞（育樂）目的之採取行為符合生活慣俗之要件前，亦即法院文化想像與立法想像明確達成一致前，法院適用文化抗辯時會選擇採取「量刑路徑」。其呈現出的現象是：法官僅在確定森林採取之文化想像與立法想像一致，亦即個案採取行為該當除罪化要件時，才會諭知判決效果較強的無罪判決。而當法官文化想像擴及、超出於立法想像之外，形式上無法符合除罪化要件時，法官會選擇自身擁有裁量權且效果較弱的量刑路徑來諭知判決。至於此現象是否存在其他案件類型及其規範意義為何，留待後續討論。

二、野生動物獵捕的文化想像：以野保法第21條之1理解為中心

根據野保法第21條之1之除罪化規定，臺灣原住民族基於其傳統文化、祭儀，而獵捕、宰殺或利用野生動物之行為，屬得阻卻違法之依法令行為。因此，法官對此規定的解釋，同樣反映其對原住

是如此，在修法前食用類型即為法官對森林採取的文化想像時，該類型可能在修法後成為除罪化規定中「出於生活慣俗之採取」的典型，而成為檢察官在偵查階段以森林採取出於生活慣俗而為不起訴處分的主要對象，使其修法後未被起訴而進入審判階段。

民族獵捕野生動物的文化想像。考慮到2021年5月司法院釋字第803號解釋限縮除罪化規定適用範圍，可能對判決分析產生影響，故於存在公開資料的2000年至該解釋作成前的範圍內，以被告為原住民且犯罪事實為構成野保法第41條非法獵捕宰殺之85件案件為對象，嘗試分析法官如何理解該除罪化規定的意義，描繪其對野生動物獵捕之文化想像。

野保法除罪化規定於2004年2月增訂，將授權主管機關訂定管理事項的法規位階提高並且將處罰規定明確化，宣示對原住民族文化權利的保障⁷⁰。以下，先鳥瞰該次修法後（下稱：修法後）的概況。表16顯示修法後至釋字803號解釋作成前，因被告主張或法官主動論及，而在審理時論及獵捕行為與文化間關係的文化抗辯相關案件約39件。這些論及文化抗辯的案件中，除獵捕對象皆為保育類動物外，從表17可見佔近85%的絕大多數獵捕目的皆為「食用」。

70 行政院2002年提出野保法修正草案時，修正條文第21條第2項為「前項第五款台灣原住民族基於其傳統文化祭典獵捕、宰殺或利用野生動物之管理事項，由中央主管機關會同原住民事務主管機關定之」，其立法理由是「為期有效規範各原住民族於其傳統文化祭典獵捕、宰殺或利用野生動物之行為，將現行依本法施行細則第二十二條授權中央主管機關會同原住民事務主管機關訂定管理事項之規定，移列為修正條文第二項」。與此同時，瓦歷斯·貝林等41人亦同時擬具修正條文第51條之1：「原住民族違反第二十一條之一第二項規定，未經主管機關許可，獵捕、宰殺或利用野生動物，供傳統文化、祭儀之用或非為買賣者，處新臺幣一千元以上一萬元以下罰鍰，本法有關刑罰之規定，不適用之」，其立法理由為「本條文係為配合行政院所提新增第二十二條之一修正條文而設……以有效規範相關行為例如誤捕、殺或利用等在行政秩序上之責任，並具體保障憲法增修條文中所揭示之原住民族文化權利」。立法紀錄參照：立法院公報，91卷33期3229號上冊，頁11-12（2002年），行政院提具條文：立法院第5屆第1會期第7次會議議案關係文書，院總第932號政府提案第8467號，頁285-286（2002年）；立法紀錄參照：立法院公報，92卷11期3285號一冊，頁5（2003年），瓦歷斯·貝林等委員提具條文：立法院第5屆第3會期第1次會議議案關係文書，院總第1749號委員提案第4747號，頁191-193（2003年）。

表16 修法後獵捕野生動物論及文化抗辯之案件判決結果

判決結果	案件數(%)
無罪路徑	4 (10.26)
量刑路徑	27 (69.23)
有罪	8 (20.51)
總計	39

資料來源：作者自製。

表17 修法後獵捕野生動物論及文化抗辯之案件獵捕目的

獵捕目的	案件數(%)
食用	33 (84.62)
祭儀食用	1 (2.56)
販賣	1 (2.56)
飼養	1 (2.56)
未提及	3 (7.69)
總計	39

資料來源：作者自製。

接著，若試圖比較修法前後法官肯定文化抗辯適用的判決路徑時，下表18顯示法官在適用文化抗辯的案件中，於修法前全面採取量刑路徑，修法後仍有近九成案件採相同路徑，而僅佔12.9%的4件案件是諭知無罪判決。為分析應如何理解此現象，勢必需要釐清採取「無罪路徑」與「量刑路徑」的差別何在。以下，本文先嘗試釐清絕大多數法官採量刑路徑的狀況下，適用此路徑之案件中犯罪事實樣貌為何。

表18 修法前後獵捕野生動物適用文化抗辯判決結果比較

判決結果	案件數	
	修法前	修法後
無罪路徑	0 (0%)	4 (12.90%)
量刑路徑	8 (100%)	27 (87.10%)
總計	8	31

資料來源：作者自製。

首先，判決採量刑路徑的意涵是法官認為個案中的獵捕行為無法適用除罪化規定而有罪，但該獵捕野生動物的行為具有實現原住民族「傳統生活習性」或「狩獵傳統」的文化面向，故即使判決被告有罪，仍有將行為反映原住民族文化傳統納入量刑評價的價值。在此脈絡下，當分析何種犯罪事實態樣無法適用野保法的除罪化規定，卻因可反映原住民族文化慣俗而納入量刑時，即可釐清法官對獵捕行為的文化想像。而且是一種與立法想像不相一致，卻更廣闊的文化想像。

由於獵捕行為反映傳統文化性質是其未被單純論知有罪的原因，故「適用量刑路徑」與「被單純論知有罪判決」的犯罪事實間的差異，即是釐清何種犯罪事實被多數法官認為具有文化意義的關鍵。對此，本文嘗試使用「邏輯斯迴歸模型」(logistic regression model)⁷¹，以修法後論及文化抗辯的39個案件中共25個犯罪事實為樣本⁷²，來探知法官對獵捕野生動物行為適用文化抗辯的關鍵因

71 此模型定義與在法學領域的運用 See ROBERT M. LAWLESS ET AL., EMPIRICAL METHODS IN LAW 344-50 (2009). 運用此模型研究臺灣法律問題，見：張永健，分割共有物判決之實證研究，收於：張永健編，2011司法制度實證研究，頁239-241（2013年）；張永健，越界建築訴訟之實證研究，中研院法學期刊，14期，頁357-363（2014年）。

72 因我國刑事案件是由「被告」與「犯罪事實」構成，數被告共同為一個犯罪事實時，會被評價為數案件。因此，雖然修法後論及文化抗辯的案件數為39個，但因存在數被告共同獵捕野生動物的共犯案件，故實際上僅有25個獵捕野生動物的犯罪事實。考慮法官評價數被告所為的一個獵捕犯罪事實時，作為評價基

素為何。故如下表19所示，此模型的應變數為「適用文化抗辯與否」(0=否，不適用；1=是，適用)。接著，因與森林採取類似，從法院對除罪化規定的適用來看，「獵捕對象種類與數量」與「獵捕目的」是判決描述犯罪事實的主要面向。故此模型自變數包括：獵捕對象為山羌、獵捕對象為山羌以外其他物種、(單一犯罪事實中)獵捕野生動物的數量，以及獵捕目的為「食用」。本模型將探知何種自變數對法官適用文化抗辯有統計上的顯著影響。同時，結合其他敘述統計資料，嘗試勾勒出法官對獵捕行為的文化想像。

表19 邏輯斯迴歸模型結果

應變數：法官適用文化抗辯（1=適用，0=不適用）	
變數名稱	基本模型
獵捕對象山羌	-2.572 (1.959)
獵捕對象其他物種	-2.115 (1.320)
獵捕動物總量	0.172 (0.467)
食用動機獵捕	-2.840* (1.474)
常數	4.212* (2.059)
Pseudo R ²	0.2107
N	25

格中未括號數字為係數，有括號數字為標準誤差
*** $p<0.001$, ** $p<0.01$, * $p<0.05$, + $p<0.1$
資料來源：作者自製。

礎的獵捕動物種類、數量與獵捕目的是相同的，對該事實的評價並不會因不同被告而有異，故宜以25個犯罪事實為迴歸分析之樣本。

首先，本文嘗試從「獵捕對象種類及數量」進行觀察。對此，受訪律師（L5）中曾有此因素可能影響法官適用文化抗辯的猜想：「我自己猜想有兩個可能，一個是有時候是因為數量問題，就是有時候可能打的數量太多了，法官有時候那個檻就會過不去，然後第二個是我很常碰到、觀察到的一個問題，就是法官都會問你：你在打的時候，你知道他是保育類動物嗎？那他可能就會說：我看眼睛以為是山羌或什麼的。然後他就會問你：你有辦法確認他不是保育類動物嗎？」。不過，現實上是否如此，則有待進一步檢驗。

詳言之，從下表20來看，二種判決路徑下的犯罪事實中，扣除為販賣牟利而獵捕食蛇龜的單一個案外，主要獵捕對象皆為山羌、山羊、臺灣獼猴與白鼻心，且同樣都以山羌為大宗，獵捕種類無明顯差異。而表19的分析也顯示，無論是獵捕山羌，或獵捕野山羊、長鬃山羊等山羌以外物種，「獵捕種類」與法官適用文化抗辯在統計上並無顯著關聯。

表20 修法後獵捕野生動物適用文化抗辯案件之獵捕對象

判決結果	獵捕對象	案件數
有罪	山羌	6
	野山羊	1
	臺灣獼猴	1
	白鼻心	1
	食蛇龜	1
量刑路徑	山羌	21
	野山羊	5
	長鬃山羊	2
	臺灣獼猴	2
	白鼻心	1

資料來源：作者自製。

接著，從y軸代表山羌數量的下圖3來看，以樣本數較充足的山羌為例，也可發現適用較嚴厲之有罪判決的個案事實中，獵捕山羌數並非較多：多為1隻，至多2隻。反之，適用較寬容之量刑路徑判決的事實中，獵捕山羌數量的中位數為3隻且數量最大值達6隻，顯然獵捕數量並非明顯影響判決路徑選擇的因素。這一點也與表19中，獵捕野生動物數量與法官適用文化抗辯在統計上並無顯著關聯的結果相呼應。若是如此，則「獵捕目的」作為反映獵捕行為文化面向的因素，就成為可能的假設。

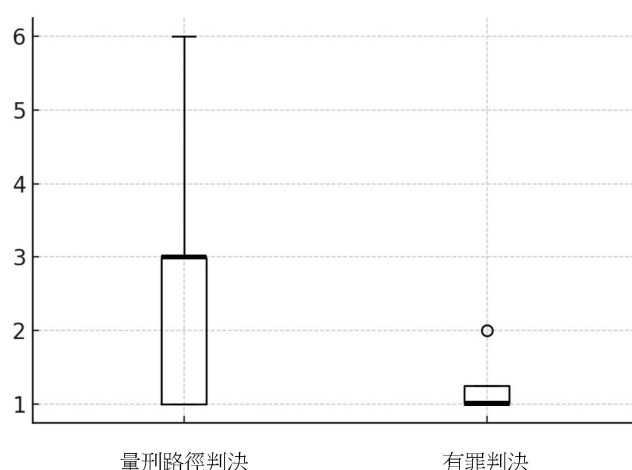


圖3 獵捕山羌數量分佈圖

資料來源：自行繪製。

關於獵捕行為目的，下表21則顯示當法官認知獵捕行為屬於文化實踐而納入量刑判斷時，扣除未提及獵取目的者外，其餘獵捕目的皆為食用。至於下表22則顯示當獵捕是出於飼養、販賣等目的時，該行為不會被法官認知為係出於文化傳統。不過，也有6件基於食用目的獵捕之案件，被法官否定文化抗辯之適用而單純諭知有罪。話雖如此，若參照下表23，從除罪化規定制定後來看，當獵捕

行為出於食用目的時，達80%的案件中法官認為獵捕行為是原住民族文化的實踐，故採量刑路徑並將獵捕文化意涵納入量刑考量。而且，若透過上開表19的迴歸分析結果，更可觀察到被告獵捕動機為「食用」，與法官適用文化抗辯在統計上存在顯著關聯。

表21 修法後量刑路徑判決之獵捕野生動物行為目的

行為目的	案件數
食用	24
未提及	3
總計	27

資料來源：作者自製。

表22 修法後有罪判決之獵捕野生動物行為目的

行為目的	案件數
食用	6
飼養	1
販賣	1
總計	8

資料來源：作者自製。

表23 修法後食用目的獵捕野生動物行為判決分佈

判決類型	案件數(%)
量刑路徑	24 (80.0)
有罪	6 (20.0)
總計	30

資料來源：作者自製。

至此，判決分析顯示：第一，為個人娛樂（飼養）與獲利（販賣）目的之獵取並未納入法官對原住民族獵取野生動物的文化想像中。第二，雖有少部分案件否認食用目的之獵捕作為文化實踐的可

能，但整體上法官表現出將獵捕動機為食用的類型納入對獵捕野生動物的文化想像中。而此分析呈現的經驗性事實，也與有受訪法官（J1）提及應審慎調查行為人是否基於販賣目的而獵捕，且謹慎判斷狩獵後的獵物是否為自用，並認為自用屬於原基法保障範疇的觀點相類似：

「那你應該是說他打了之後才去賣，去抓那一塊嘛。」、「其實我覺得警察也不想，也沒有好好地去追他到後面到底是要賣還是怎麼樣。」、「像我今天要去打獵，打完之後，到底這個東西是不是自用，因為自用，就會有原基法的問題。」（J1）

若再將上述修法後現象，與除罪化規定修法前法官基於獵捕行為反映傳統文化慣俗而採量刑路徑的案件進行對照時，可更清楚觀察法官對獵捕行為的文化想像。如下表24中，在未制定除罪化規定前，為食用或祭儀中分享食物而獵捕是法官認知與文化慣俗相關而可納入量刑考量的類型。亦即，修法前法官對獵捕行為文化想像的樣貌，與修法後的現況相同。其中應注意的是，為祭儀食用而獵捕已被納入除罪化要件適用範圍中，故修法後此類型不單未出現在法官量刑路徑的適用對象中，於審判階段幾乎不復見此類型案件。以下，將上述觀察結合修法後無罪路徑案件類型揭露的資訊，對獵捕野生動物案件的實證觀察可總結兩點說明：

表24 修法前採量刑路徑之獵捕野生動物行為目的

行為目的	案件數
食用	5
祭儀食用	1
未提及	2
總計	8

資料來源：作者自製。

第一，關於法官文化想像本身。在2004年將「為祭儀獵捕」納入除罪化規定適用範圍後，由此類型幾乎消失在審判階段，及在審判出現即被諭知無罪（如下表25）來看，可研判此類型應已穩定成為法官對獵捕行為文化想像的內容，也再次凸顯法官依循立法實證性的傾向與文化抗辯適用間的關聯。接著，從修法前後比較可發現「為食用獵捕」持續被法官認定為狩獵文化實踐的主要類型，且即使修法未將其納入除罪化適用範圍，修法後仍呈現此類型案件與法官適用文化抗辯在統計上顯著關聯的現象。亦即存在絕大多數此類型案件被採量刑路徑，並於量刑判斷中考量文化因素的發展趨勢。再結合前述如「為販賣之獵捕」被排除於文化想像的說明，可以說法院目前對獵捕行為形成分歧較小的文化想像：「為祭儀使用或生活中自用且非營利目的之獵捕行為」。

事實上，表25中的3個為食用而獵捕之無罪案件，可能即是反映法官此文化想像並試圖實踐的案例。詳言之，修法後諭知獵捕行為無罪的判決中，除1個是該當除罪化規定者外，尚有3則判決是在被告為食用而獵捕的情況下，法官在除罪化規定文義範圍內廣義解釋該規定內涵，使其實質適用於「非營利自用的獵捕行為」，進而作出無罪判決且為上級審所維持。而此判決論理，或許正可佐證部分法官對獵捕行為已形成前段所推論的文化想像。

表25 修法後採無罪路徑之獵捕野生動物案件

無罪理由	案件數	獵捕目的
廣義解釋除罪化規定（非營利自用）	3	食用
符合除罪化規定	1	祭儀食用
總計	4	

資料來源：作者自製。

第二，關於法官與立法者文化想像的差異及法官判決路徑選擇的關係。從修法前後發展來看，修法前被納入量刑路徑適用的「為

祭儀獵捕」，已被除罪化要件所涵括，應可理解為立法者與法官對此類型作為文化實踐已達一致，其已成為法官對獵捕文化想像的內容。這部分可謂與森林採取類似，呈現立法與司法趨於一致的發展軌跡。不過，自修法前迄今可能已成為絕大多數法官文化想像內容的「為食用獵捕」，目前仍非屬除罪化規定適用對象。換言之，現況可理解為多數法官文化想像的範圍與立法者不一致，且擴及立法想像之外的現象。

而此狀況可說是分析法官適用文化抗辯時判決路徑選擇的切入點。一方面，從「為祭儀獵捕」類型來看，在修法前法官與立法者文化想像不一致時，法官僅會選擇將其納入量刑判斷，但在除罪化規定明定此類型阻卻違法後，法官會選擇效果較強的無罪判決。另一方面，從「為食用獵捕」類型來看，於法官肯定其適用文化抗辯的27件案件中，雖有極少數諭知無罪，但佔88.89%的絕大多數案件是採取量刑路徑處理。此一比較顯示出「法官與立法者文化想像一致性」與「法官判決路徑」間的互動關係：當法官文化想像擴及、超出於立法想像，即使肯定文化抗辯適用，多數仍僅願採量刑路徑；當雙方想像一致，才可能諭知效果較強的無罪判決。

三、槍枝持有使用的文化想像：以槍砲條例第20條理解為中心

根據槍砲條例第20條的除罪化規定，原住民未經許可製造、運輸或持有自製獵槍（含其主要組成零件或彈藥）或自製魚槍，若是供作生活工具之用者，屬得阻卻違法之依法令行為而不適用刑罰規定。因此，法官如何理解此規定的意涵，即反映其對原住民族製造、運輸與持有槍枝的文化想像。對此，本文以1999年至2023年間原住民被告所為犯罪事實構成現行槍砲條例第8條（2005年前構成修正前同條例第11條）之未經許可製造、販賣、運輸、持有、寄藏

（這些類型以下簡稱：槍枝持有行為）該條所列種類槍枝者為範圍，初步整理出138件案件。

槍砲條例的除罪化規定是在2001年11月修法訂定，三讀通過的立法理由是考量到原住民使用槍枝有其生活上需要，而以法律制裁持有生活必需品，乃是對於原住民人權的嚴重傷害⁷³，故將原本僅設有減輕或免除其刑的規定，正式除罪化而改為處以罰鍰⁷⁴。由此修法理由可知，不同於野保法的除罪化規定是出自尊重原住民族生活傳統或文化權利的「尊重文化思維」，此項除罪化規定的增訂，則偏向以原住民族「生活上需要」的經濟思維為出發點。這一點是觀察法院如何適用本規定時，須留意的面向。

以下，先鳥瞰該次修法後（下稱：修法後）的概況。表26顯示修法後經被告提出或法官自行適用而於審理中論及文化抗辯之案件共56件，超過二分之一的案件遭法院諭知有罪，至於法官接受文化抗辯案件則有24件。如表27所示，法官適用文化抗辯的案件，近八成案件被諭知無罪，僅5個案件是採量刑路徑處理。

73 2001年三讀通過立法理由為：「原住民使用獵槍是有其生活上之需要，以法律制裁持有生活必需品之行為，是對原住民人權之嚴重傷害。因此，原住民持有獵槍者只要登記即可合法，而未經登記者則以行政罰加以處罰，這不但符合行政程序法之規定，也保障了原住民基本之生活權益」。

74 行政院2000年提出槍砲條例修正草案時，並未將第20條作為除罪化規定。而是瓦歷斯·貝林等32人擬具修正條文第20條第1項為「原住民未經許可，製造、運輸、陳列或持有自製之獵槍，供作生活工具之用者，不適用本條例之規定。」、第3項為「獵槍、漁槍、刀械專供生活習慣特殊國民之生活工具者，其管理辦法由中央主管機關定之」。當時立法說明表示「給予除罪化……理由如下：一、因為既然屬於供作生活上及文化上工具之用，而無據為犯罪工具的意圖。二、未經許可者應循本條文第三項授權命令的行政罰及其行政程序予以補正即可。三、以落實憲法增修條文及符合本條例多元文化主義的政策目標與規範意旨」。立法紀錄參照：立法院公報，89卷33期3092號上冊，頁4（2000年），瓦歷斯·貝林等委員提具條文：立法院第8屆第3會期第22次會議議案關係文書，院總字第1187號委員提案3039號，頁146-148（2000年）。立法紀錄參照：立法院公報，90卷14期3148號上冊，頁17（2001年），行政院提具條文：立法院第4屆第3會期第22次會議議案關係文書，院總第1187號政府提案第7519號，頁579-586（2000年）。

表26 修法後持有槍枝論及文化抗辯之案件判決結果

判決結果	案件數(%)
無罪	19 (33.93)
量刑路徑	5 (8.93)
有罪	32 (57.14)
總計	56

資料來源：作者自製。

表27 修法前後持有槍枝適用文化抗辯判決結果比較

判決結果	案件數	
	修法前	修法後
無罪	0 (0%)	19 (79.17%)
量刑路徑	31(100%)	5 (20.83 %)
總計	31	24

資料來源：作者自製。

在此，值得注意的是，不同於森林法與野保法的除罪化規定是增訂新法，槍砲條例第20條於2001年修法前即已存在，差別在於修法前僅對供作生活之用的槍枝持有行為賦予減免刑罰效果，修法後才改賦予無罪效果。而修法前適用文化抗辯者全部採用量刑路徑，但修法後適用文化抗辯者有近八成是被諭知無罪，也反映出槍枝持有案件被肯認適用文化抗辯時，法院處理路徑多依當時條例設定的效果行之。雖然無法據此推論該修法與法官選擇法律效果間的因果關係，但透過比較修法前採量刑路徑案件與修法後無罪案件間的犯罪事實組成，仍是嘗試釐清法官文化想像的起點。

由於在槍砲條例的除罪化規定中，「槍枝類型」與「持有目的（供作生活工具用）」是兩個最主要的要件，故以下先觀察這些要件與有罪、無罪判決間的關係。而從表28與29的對照可發現：第一，因持有非自製獵槍而被判決有罪者僅佔有罪案件的10.81%，亦即近

九成的有罪案件都是在持有槍枝型態被認定合法的前提下，因槍枝持有目的非作為生活工具之用而獲判有罪。再對照適用除罪化規定而諭知無罪者，皆是以槍枝供生活工具用為由，可發現「持有目的」是除罪化規定得否適用的關鍵因素。第二，即使在因非持有自製獵槍而獲判有罪的案件中，也是以持有槍枝目的作為是否將文化因素納入量刑考量的區分基準。亦即，為狩獵或保護農地持槍時，槍枝被認定為生活工具之用而影響量刑判斷，惟若出於維修等非供生活工具使用之目的時則否⁷⁵。

表28 修法後持有槍枝之文化抗辯案件有罪理由*

判決理由	判決類型	案件數(%)	持槍目的
非供生活工具用		33 (89.19)	
	有罪	30	
	量刑路徑	3	
非持有自製獵槍		4 (10.81)	
	有罪	2	維修
	量刑路徑	2	狩獵、保護農地
總計		37	

* 包含「有罪判決」與「量刑路徑判決」

資料來源：作者自製。

表29 修法後持有槍枝之文化抗辯案件無罪理由

判決理由	判決類型	案件數
供生活工具用	無罪	19

資料來源：作者自製。

⁷⁵ 「維修獵槍」時獵槍是否屬原住民族生活工具，本文認為應可肯認，故法院判決是否合理，未來有檢討必要。

綜合來看，相較持有槍枝類型，持有槍枝目的在論罪與科刑層面的影響性，使其更適於作為分析法官對原住民持有槍枝文化想像的切入點。而此觀察也可見於下開訪談資料中，如有法官曾直言「供作生活工具用」的解釋寬嚴乃是適用除罪化規定與否的關鍵。這使得哪些目的持槍可被法院理解為「供作生活工具用」並可適用文化抗辯，成為重要課題。

「槍砲的問題也是如此，只是說我覺得供生活化的部分，就是我覺得有時候是可能立法者現在設計的那個規定，大家在解釋上會傾向於一種：是到底要放多寬去解釋問題？」
(J2)

關於上開課題，下表30顯示修法後審判中文化抗辯為被告或法官論及的案件中，在先忽略狩獵模式差異的前提下，可先將持槍目的粗略區分為「狩獵」、「為保護農地而驅趕動物」與「非出於狩獵或保護農地者」，而最後一項主要包括娛樂、保管、贈與他人、受託維修測試等目的。但若對照表31所示法官適用文化抗辯的類型，可發現僅目的出於「狩獵」或「保護農地」者有適用文化抗辯的可能，非此二者則否。若從此二目的的內容來看，僅槍枝作用於野生動物且與漁獵或農耕相關者，才有被肯認為傳統文化實踐的可能。

表30 修法後持有槍枝論及文化抗辯案件組成（目的基準）

持槍目的	案件數(%)
狩獵	23 (41.07)
祭儀狩獵	4
常態狩獵	5
非常態狩獵	14
保護農地	10 (17.86)
非關狩獵、農耕	23 (41.07)
總計	56

資料來源：作者自製。

表31 修法後持有槍枝適用文化抗辯案件組成

持槍目的	判決類型	案件數
保護農地		7
	無罪	6
	量刑路徑	1
狩獵		17
	無罪	14
	量刑路徑	3
總計		24

資料來源：作者自製。

而若將視野擴及修法前，從下表32可發現除2001年修法後才納入除罪化規定的魚槍捕魚，提出文化抗辯最主要的類型還是出於狩獵與保護農地目的者。而表33則顯示與修法後相同現象，亦即能被法官評價為持槍供生活工具之用者，除僅一件是現已未見的山區工作防身目的，其餘同樣限定在狩獵或保護農地目的。換言之，無論修法前後，本文所能觀察的判決顯示，法院對屬於生活工具之用的持槍行為，穩定地限定在出於狩獵或保護農地等目的。換言之，從目前法院承認為生活工具之用的類型來看，反映其文化想像中原住民持槍文化必然與「狩獵」或「農耕」相連結。

表32 修法前持有槍枝論及文化抗辯案件組成（目的基準）

持槍目的	案件數(%)
保護農地	16 (50.0)
狩獵	8 (25.0)
山區防身	2 (6.25)
捕魚	1 (3.13)
未提及	5 (15.63)
總計	32

資料來源：作者自製。

表33 修法前持有槍枝適用文化抗辯案件組成

量刑理由	持槍目的	案件數
供生活工具用 (成文減免刑罰規定)		23
	保護農地	16
	狩獵	6
	祭儀狩獵	1
	常態狩獵	4
	非常態狩獵	1
	山區防身	1
實現傳統狩獵文化		3
	非常態狩獵	2
	山區防身	1
未提及		5
總計		31

資料來源：作者自製。

然而，若注意到修法前為狩獵而持槍並非一律被認定為供生活工具之用，以及修法後為狩獵而持槍時仍可能獲得有罪判決，這代表在法院認知中，狩獵持槍並非必然與為生活工具之用劃上等號，即使狩獵持槍仍有被法院認定為非傳統文化實踐的可能。如此一來，勢必有對狩獵持槍進行更細緻觀察的必要。

對此，雖然從下表34可知狩獵持槍半數以上獲判無罪，但值得注意者為獲判有罪的情形。以表35對採量刑路徑判決的案件整理為契機，可發現雖然都出於狩獵目的，但客觀上狩獵情狀差異可能會影響法官評價。以下對照表36的分類進行說明。首先，祭儀狩獵係指原住民因準備或參與祭儀而使用槍枝狩獵，從表35中原住民持非自製獵槍獲判有罪但法官將祭儀狩獵納入量刑考量的案件，可發現法官可能肯認此類型與傳統文化的關係。接著，常態狩獵係指法官認為被告以狩獵為生而持續狩獵或有規律性固定參加狩獵活動等，可認定其有狩獵習慣的狀況。而與祭儀狩獵類似，表35其中一案件

即是被告因一起狩獵的目的而提供他人槍枝而獲判有罪，但法官將其因平日常態狩獵習慣而持槍納入量刑考量。最後，非常態狩獵是指被告非以狩獵為生且未規律性狩獵者，如職業非獵人但隨機二、三次狩獵的狀況。對此，表35中即有法官認為持槍非為生活工具之用而判決有罪，僅考慮被告受傳統文化影響才狩獵而加以減刑。以此觀察為起點，為描述法官文化想像，有從狩獵情狀切入觀察的必要。

表34 修法後狩獵目的持槍案件判決結果

判決結果	案件數(%)
無罪	13 (56.52)
量刑路徑	4 (17.39)
有罪	6 (26.09)
總計	23

資料來源：作者自製。

表35 修法後狩獵目的持槍量刑路徑判決案件整理

有罪理由	量刑考量理由	案件數
非自製獵槍	祭儀狩獵	1 ⁷⁶
販售槍枝給他人（非供生活工具之用）	狩獵動機， 且平時習慣性狩獵	1 ⁷⁷
非常態狩獵（非供生活工具之用）	狩獵文化影響	2 ⁷⁸

資料來源：作者自製。

76 參照：臺灣花蓮地方法院104年度重訴字第4號刑事判決。

77 參照：臺灣花蓮地方法院95年度訴字第346號刑事判決。

78 參照：臺灣花蓮地方法院98年度訴字第440號刑事判決、臺灣花蓮地方法院110年度原訴字第81號刑事判決。

表36 狩獵目的持槍客觀狩獵情狀分類

分類	情狀	案件數
祭儀狩獵	因祭儀而持槍狩獵	4
常態狩獵	1. 以狩獵為生而具持續性 2. 規律性參與狩獵	5
非常態狩獵	非以狩獵為生且無固定規律性狩獵	14

資料來源：作者自製。

下表37中，不區分法官肯定狩獵持槍作為生活工具之用是在論罪或科刑階段的前提下，可見原住民為祭儀而持槍狩獵必然被法院肯認為供作生活工具之用。對此，從為祭儀獵捕野生動物的合法性被肯定來看，法院認定出於此目的持槍為合法文化實踐，具有邏輯上一致性。而與祭儀狩獵類似的狀況也發生在常態狩獵中，凡被告以狩獵為生或規律性參與狩獵活動時，法院皆根據被告有狩獵習慣而肯認持槍為供生活工具用。較特別的是非常態狩獵的狀況，當法院認為從被告職業別來看非以狩獵為生或被告只是單次隨機狩獵時，明顯出現立場分歧：有認為持槍仍屬生活工具之用者，但也有採否定立場者。而在後者部分，表38顯示多數是基於被告欠缺持續性或規律性狩獵習慣而否定此持槍情狀為文化實踐，少數則是以非關祭儀為由而拒絕文化抗辯，而這兩個立場也正對應到法院肯認祭儀狩獵與常態狩獵為供作生活工具用的觀點。

表37 狩獵持槍情狀與供生活工具用分析

狩獵持槍情狀	供作生活工具之用	案件數
祭儀狩獵		4
	肯定	4
	否定	0
常態狩獵		5
	肯定	5
	否定	0
非常態狩獵		14
	肯定	6
	否定	8

資料來源：作者自製。

表38 非常態狩獵持槍非供生活工具用理由

理由	案件數
與祭儀無關	2
欠缺狩獵習慣	6

資料來源：作者自製。

總結以上觀察，可將法院目前判斷狩獵持槍是否屬生活工具之用分為三種觀點。第一，祭儀狩獵說（6個案件），著重於持槍狩獵與祭儀間的關聯。第二，狩獵習慣說（11個案件），著重於被告是否形成持續性、規律性的狩獵習慣，為最多案件採用的標準。在訪談資料中也有受訪法官（J2）採此看法，提到：「比如說供生活使用，那一定是真的要祭儀使用嗎？或是一定是要為了傳統祭祀活動打獵使用嗎？我覺得好像這個解釋上有點太過限縮，因為生活本身就是一種……原住民不是只有在祭儀才在生活，所以我覺得可能是解釋上的問題。」，批評祭祀狩獵說有過於限縮解釋的問題，並指出應回歸「供作生活工具」的目的來解釋。第三，文化多樣化說（6個案件），否認狩獵持槍必然連結祭儀，也不認為須以狩獵習慣

為前提，凡原住民狩獵持槍都可視為文化實踐。在訪談中，如有法官（J4）提到：「原住民……如果生活工具說有在狩獵，那個狩獵基本上當然不需要說，像傳統的原住民是以狩獵為唯一的生存手段嘛，那我閒暇之餘去狩獵、練膽、試煉、分工，然後打到東西，大家一起來分食，聯絡感情，這也算是一部分。」，指出現今原住民非以狩獵為唯一生存手段，閒暇狩獵也可適用除罪化規定，即是類似本說的觀點。

由狩獵存在多樣化的觀點來看，可注意到雖然在營生也是文化實踐一環的理解下，槍砲條例中除罪化規定的立法階段，可說是根據經濟思維來形成「槍枝為原住民族生活上需要」的文化想像。但除了「狩獵習慣說」與該思維尚有連結外，「祭儀狩獵說」與「文化多樣說」顯然偏向尊重文化思維為中心，而與該思維無涉。亦即，在法庭活動的積累中，雖然法官仍在除罪化要件設定的「槍枝作為生活工具使用」的框架內形塑文化想像，但該想像與立法原初的思維已有落差。

最終，目光來到為保護農地持槍的情形，雖然多數案件獲得無罪判決，但仍有少數有罪案件。根據下表39，可發現法官在狩獵持槍中的文化想像延伸到保護農地持槍的狀況。詳言之，3件被單純論知有罪的案件是來自於法官認為為保護農地而使用槍枝驅趕動物，由於與祭儀無關，故非供生活工具之用的範圍，這明顯是祭儀狩獵說的延伸，也顯示法官對原住民族生活必然連結祭儀的想像，限縮狩獵或保護農地與生活連結的想像。至於因非自製獵槍被論知有罪的案件，則是因法官認為被告例行性狩獵而有狩獵習慣，故將此文化因素納入量刑判斷，而此明顯連結到狩獵習慣說。

表39 保護農地目的持槍案件整理分析

判決結果	案件數	有罪理由	量刑考量理由
無罪	6		
量刑路徑	1	非自製獵槍	被告具有狩獵習慣
有罪	3	與祭儀無關	
總計	10		

資料來源：作者自製。

透過以上觀察，可歸納出兩點須說明之處：第一，先不論狩獵或農耕的生活想像是否過度窄化，雖然法官普遍形成槍枝必然使用於農事或狩獵的粗略生活想像，但因為法官是在立法設定的條文框架下，以對原住民族生活樣貌的想像為基礎，據此構想槍枝在該生活想像中的位置，進而判斷所審理個案中持有槍枝是否屬於供生活工具之用、是否屬於傳統文化實踐的內容。因此，當法官對生活更具體細緻的想像欠缺一致性時，會導致法官對槍枝持有難以形成單一的文化想像，也導致除罪化規定適用與否的實際操作出現分歧的判準。

第二，雖然對原住民族持槍狩獵或進行農事的具體想像有所分歧，但不同於森林採取與野生動物獵捕類型都出現法官想像廣於立法想像的情形，法院對槍枝持有的文化想像雖偏離立法階段的原初思維，但各觀點明顯仍被限定在立法者設定的「槍枝作為生活工具使用」的法規範框架中，未能實質上跳脫立法想像。若再加上法官又自行將該生活想像窄化於狩獵、農耕或祭儀相關，其明顯呈現出法官對槍枝持有緊縮文化想像，而與森林採取、野生動物獵捕中擴張想像的發展趨勢相反。在此脈絡下，本文猜想，對比法官在森林採取與野生動物獵捕案件中，當法官文化想像廣於立法想像時採用量刑路徑來處理的行為傾向，可能正因法官對槍枝持有的文化想像經歷立法與自身的雙重限定，在其想像必然限縮於立法者設定範圍內的情況下，槍枝持有案件明顯作出較多無罪判決。

四、要件理解實證結果的規範意義

對照下圖4，本文第參部分指出法官適用文化抗辯案件類型侷限在立法除罪範疇（A）中，亦即立法想像中原住民族文化實踐行為的可能類型。不過，從該範疇中各除罪化規定的明文規範可知，立法者並非肯認所有符合A範疇內案件類型的行為都必然適用文化抗辯，僅有符合各除罪化要件T的行為方得適用。亦即以T為分界（圖4虛線），可分為符合要件故可阻卻違法而無罪的A1，以及未符合要件而無法適用除罪化規定的A2，其中前者對應立法者關於原住民族文化實踐的立法想像。以下，本文分就「想像差異」與「路徑選擇」兩個面向，說明對法官於各案件類型中如何理解除罪化要件의觀察結果。

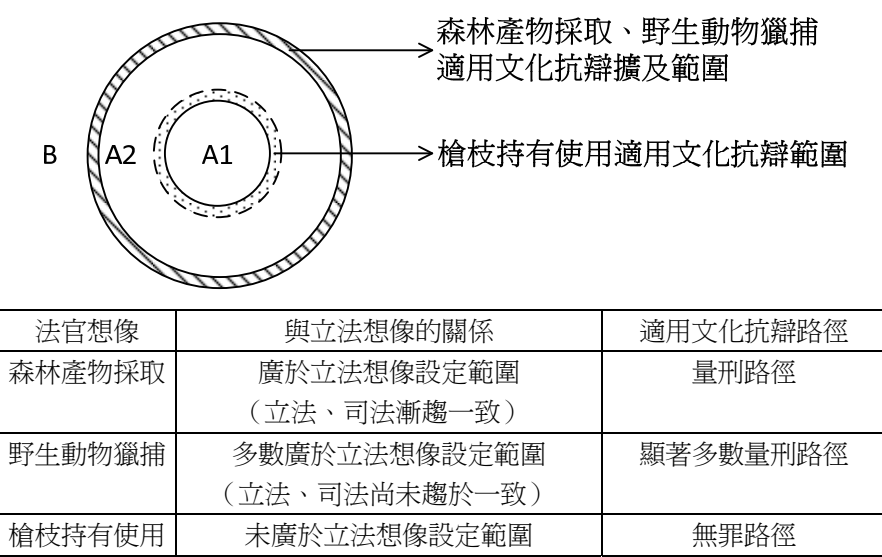


圖4 要件理解與判決路徑示意圖

資料來源：自行繪製。

首先，從法官與立法者對文化的「想像差異」談起。在此面向，無論是森林採取或野生動物獵捕中，法官肯認文化抗辯適用於這二種行為時，其設想中該當文化實踐的行為類型，並未完全受限於立法者透過除罪化要件劃定的界限，因而呈現圖4中法官文化想像範圍（A2）大於立法者（A1）的情況。甚至，在森林採取部分，2019年立法的採取規則還將法院早已承認文化抗辯適用的醫療、育樂目的等採取行為，明文納入除罪化要件的適用對象，呈現立法與法官想像趨於一致的現象。反之，在槍枝持有部分，法官僅肯認在狩獵或保護農地時持有槍枝者，因屬於為生活目的而使用之工具，故適用文化抗辯。這明顯呈現文化抗辯適用侷限在符合除罪化要件的情形，亦即如圖4中法官文化想像限定於立法想像範圍（A1）內的狀況。

接著，從法官適用文化抗辯時的「路徑選擇」切入，可發現其與上述文化想像範圍間差異有對應性。詳言之，僅適用除罪化規定的範圍（A1）內，法官有可能透過依法令行為阻卻違法來選擇無罪路徑，一旦法官認為適用文化抗辯的行為類型超出除罪化要件可涵攝的範圍（A2），法官即會改選擇量刑路徑來讓文化抗辯有適用於審理程序的空間。在此脈絡下，在槍枝持有案件中，由於法官文化想像限定於立法想像範圍內，故法官適用文化抗辯時多可直接適用除罪化規定而諭知無罪，也造成此案件類型適用文化抗辯時無罪判決較多的現象。相對地，在另外二種案件類型中，由於法官文化想像超過立法想像劃定的界限，故法官想適用文化抗辯與考量原住民文化因素時，僅能在量刑判斷中處理，可能因而造成此二類型案件極少出現無罪判決，而多集中於量刑階段適用文化抗辯的現象。

總結來說，上述現象可簡述為：法官對三種案件類型中適用文化抗辯與否的理解未必都受限於立法者（想像差異面向），導致對各類型個案適用文化抗辯時的主要路徑選擇不同（路徑選擇面向）。如此一來，二者中居於關鍵位置的顯然是想像差異的面向，

亦即以法官與立法想像的關係作為決定法官路徑選擇的前提。至此，對比法官在案件適用範疇完全受限於立法者的傾向，關鍵問題將是：「為何法官在文化抗辯適用案件類型上受限於立法想像，但在要件理解上卻未必如此」、「為何不同案件類型中，法官與立法想像的關係有別」。為回應此問題，以下先從路徑選擇的規範意義談起，藉此指出回答問題的關鍵。

（一）法官與立法文化想像差異的起源：從路徑選擇的規範意義談起

在此，延續採用規則與原則之分來詮釋文化抗辯適用範疇的進路，嘗試就上述有關路徑選擇的經驗性事實，賦予其規範意涵。如前所述，針對法官將文化抗辯適用限定於立法除罪範疇，且透過依法令行為阻卻違法來論知無罪的經驗性事實，本文將其規範意義理解為：多元文化作為與法益保護進行衡量時較難勝出之原則，唯有透過具立法權威論據而作為「規則」的除罪化規定迴避原則衡量，才可能在個案中被適用。以此為前提，在法官與立法想像一致的範圍（A1），當法官對槍枝持有行為所反映多元文化意涵之理解，與立法制定的除罪化要件相符，其自可不為原則衡量而直接適用除罪化規定來論知無罪，透過立法權威使該行為被視為現行法秩序一環。

反之在法官文化想像廣於立法者的狀況（A2），由於法官理解中可適用文化抗辯、具多元文化意涵的森林採取或野生動物獵捕行為，可能無法該當根據立法想像制定的除罪化要件而無法論知無罪。此時法官選擇量刑路徑的規範意義或可理解為：因多元文化與法益保護進行原則衡量時難以勝出，故二種行為可能無法適用除罪化規定，無法被立法權威認可為法秩序一環而難有阻卻違法適用。但被告被判斷有罪後，科刑階段根據各因子決定應施加多少不利益於行為人的量刑判斷中，各因子彼此間並非處於衡量後「擇一適

用、另一排除」的關係，而是在共存狀態下根據量刑目的衡量各因子影響刑罰的方式與權重，綜合各因子判斷最終量刑。如此一來，若法官選擇文化因素作為量刑因子，其適用不以與犯情等其他因子的衡量間勝出為要，而只需論證其與刑罰輕重間的關聯性即可，即令與其他因子衡量，也僅是決定各自對刑度的影響。前述若干法院判決以文化因素可能影響期待可能性為由來將其納入量刑判斷，即是依此路徑迴避原則衡量，但仍適用文化抗辯的表現。當然，因此路徑下的文化抗辯適用，未使行為實質上被評價為合於現行法秩序，故可謂效果較弱的適用路徑。

若肯認以上對路徑選擇規範意義的詮釋，則可看出：無論採無罪或量刑路徑，法官論證文化抗辯適用的前提，必然是法官認為該個案行為得反映多元文化原則的適用可能，亦即認知行為本身蘊含原住民文化意涵。而由判決觀察可知，面對森林採取、野生動物獵捕與槍枝持有行為，法官都呈現出根據個案「行為目的」來區辨特定行為有無蘊含文化意涵的傾向。對此，我們可以想見法官是根據其對原住民族文化的理解，也就是以法官文化想像為依據，來評價出於何種目的之行為具有文化意涵。

那麼，在此就必須提出下個問題：作為判斷行為有無文化意涵的基準，法官文化想像的內涵為何。此問題也將影響到本文核心的提問：作為決定不同案件中法官路徑選擇的前提，為何不同案件類型中，法官文化想像與立法想像的相互關係會各有差異？

（二）作為法官文化想像內涵的「生活想像」：在傳統文化與生活方式之間

關於法官文化想像，本文認為是以對原住民族生活形式的「生活想像」為內涵。詳言之，在本文關於何種行為目的可適用文化抗辯的觀察中，包括為了食用、醫療或育樂而森林採取，為祭儀或食用而獵捕野生動物，或者為狩獵或保護農地而持有槍枝，都可觀察

到法官判斷個案中行為是否可適用文化抗辯時，係以該行為是否屬於具文化意涵的原住民族生活形式作為認定基準。如前所示，即有法官在訪談中論及槍砲條例除罪化規定的適用時，顯露出是以對現代原住民族異於傳統的生活形式想像為基礎。

以最具代表性的槍枝持有案件為例，受法官承認為「供作生活工具之用」的持槍目的普遍限於狩獵或保護農地。此現象反映出：唯有屬於「原住民族文化生活形式」的槍枝持有，才有適用文化抗辯的可能。而在法官想像中，這種具文化意涵的生活形式必然與狩獵或農事連結，顯示出農耕或狩獵是法官對具有原住民族文化之生活形式的想像。此外，若更進一步觀察判決文字，可發現被廣泛承認適用文化抗辯且為2019年採取規則立法納入的「為食用而森林採取」，判決常出現的描述是「原住民族向來與大自然存有共存共榮之關係，舉凡食衣住行無一不與自然環境緊密相連，形成靠山吃山之特殊生活方式」⁷⁹。這同樣顯示法官是以森林採取是否反映「與自然共榮共存」、「與自然緊密相連」等性質，亦即是否屬於其想像中原住民族靠山吃山的生活形式，來決定該行為是否適用文化抗辯。

至於上述現象的產生，其中一種可能是法官的文化想像（或生活想像）受各除罪化要件影響。如前一部分提到，立法者針對森林採取等案件類型設定除罪化規定，標示出該案件類型有成立文化抗辯的可能，判決觀察顯示其同時構成法官適用文化抗辯的外部界限，成為形塑臺灣版文化趨同的機制之一。若除罪化規定的「有無」具有影響法官行為的效果，則除罪化要件的「內容」，可能也存在相似的影響性：除罪化要件對可適用文化抗辯之行為態樣的描述，使該態樣具有立法實證性，讓依立法實證性認事用法的法官，趨向根據該描述來理解何種行為具文化意涵。

79 參照：臺灣花蓮地方法院105年度原訴字第26號刑事判決。

而此猜想可能為真的理由，是從目前除罪化規定來看，無論立法階段是根據經濟思維或尊重文化思維來設定要件，包括森林法中「生活慣俗需要」之要件、槍砲條例中「供作生活工具之用」的要件，或法官在野保法案件中對「傳統生活方式與習性」的描述，都與「生活」的概念緊密相關。而判決中也可觀察到，法官並未受制立法原初的思維，而是聚焦在行為目的，判斷森林採取是否屬於與自然連結的生活方式、野生動物獵捕是否出於傳統生活習性，以及槍枝持有是否作為生活工具，進而決定文化抗辯適用與否。此情況正顯示出法官對個案行為有無文化意涵的理解，在依立法實證性行事的傾向下，受到以「生活」概念為中心的除罪化要件所影響。

不過，在除罪化要件的影響外，仍應注意可能因法官存在不同的原住民族生活想像，而使相異的文化想像反映於分歧的法律意見中。例如法官雖然普遍想像原住民族狩獵、農耕的傳統生活形式，但從何種狩獵持槍符合供作生活工具之用的意見分歧中，可窺見法官對狩獵生活又產生「祭祀時才會狩獵」或「狩獵是以之維生而持續進行」等不同形式的想像。而這些想像最終也反映在如打零工、工程人員持槍狩獵時，槍枝是否為生活工具的分歧認定上⁸⁰。換言之，當法官圍繞自然資源利用或槍枝持有來描述對「生活」的想像時，其指的是對傳統文化生活或納入現代社會生活形式的想像？是限於自用還是要納入交易獲利的形式？是否須形成慣常反覆實施的習慣？這些問題都涉及對「原住民族／非原住民族」生活想像的差異，也成為適用文化抗辯時文化想像的核心。

另外，除生活形式本身可能存在分歧想像，對單一行為及其背後整體生活形式的想像能否分離，也會是問題所在。如最高法院明確表示持槍恐嚇之持有槍枝行為，無法適用槍砲條例的除罪化規

80 參照：臺灣花蓮地方法院101年度訴字第96號刑事判決。

定⁸¹，其判決意旨認為恐嚇已然溢出「供作生活工具之用」的範疇，顯然也是以生活想像作為文化抗辯適用基礎的思維。然而，「單一的恐嚇用槍行為非屬原住民族生活形式，故該槍枝非作為生活工具之用」的論述雖看似合理，但若該槍枝為被告平時隨手可得並持續、規律使用於狩獵，是否該次使用完全與生活形式無關，仍有再研議的空間。類似例子還包括下述訪談意見，呈現出當法官評價持槍恐嚇的單一行為時的疑問：是否要將槍理解為與菜刀相同的生活工具？是否對槍枝在生活中角色賦予特殊地位？簡言之，日常生活作為針對食衣住行各種活動的整體想像，在評價整體生活歷程中之特定行為是否適用文化抗辯時，能否輕易將其理解為與整體生活脈絡割裂的單一行為來評價，這同樣牽涉到應如何形塑生活想像的課題。

「一用槍恐嚇你，就不再是恐嚇罪，就直接跳三年。我用菜刀恐嚇你是拘役罰金。用槍恐嚇你突然就變三年以上，最高法院解釋起來是濫用槍。我覺得不合理，部落或原住民傳統文化，槍和菜刀是一樣的。今天國家說槍很危險，那是國家，不是原住民族的想法。對我原住民來說，兩種是一樣的，都是用生活工具恐嚇你。都是用生活工具恐嚇，為什麼會跳三年以上，不得緩刑、不得易科罰金，一定得去坐牢，多可怕。」(L2)

「平常都有狩獵，而拿槍去恐嚇別人……採取阻卻違法事由，槍砲條例二十條，但它被中斷了，是繼續犯。為什麼中斷？法院是認為『不是一日合法、終身合法』。中斷的原

81 參照最高法院111年度台上字第2810號刑事判決：「如有溢出文化上或生活上工具之範圍而使用，甚且持供不法用途者，因已偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活之價值內涵，該阻卻違法狀態即遭中止，而具刑罰之違法性。否則，無異容許原住民合法製造、運輸或持有槍枝後，即可享有永久不受原住民狩獵文化或生活需求節制而恣意使用槍枝之權限，此當非社會所認同或允許之權利。」

因是，你使用這把槍，非供生活使用、跟文化無關的時候，就會中斷了。」(J4)

若從人類學角度來理解，上述關於「生活」的想像，可謂源自於墾殖者與原住民族的族群界線，透過「種族的文化化」⁸² (the culturalization of race) 作用於司法判決，展現對原住民族的特定想像，也就是司法部門對「原住民性」的理解。如同國外研究往往顯示此理解與自然環境存在高度親近性，並從中描述或建構法律文件中的權利與利益⁸³。我國判決也呈現出法官將對原住民族的生活想像，連結到原住民族與自然環境親近性的類似現象，顯例包括：環繞自然資源利用來理解原住民族傳統生活形式，以及將與自然環境關係薄弱的行為認定為與具文化性質的整體生活分割評價。同時，此現象也來自知識形塑與法律技術的彼此作用：立法者從「自然資源利用」角度制定除罪化規定，表明與建構立法想像的「原住民性」，同時可能影響司法部門形塑生活的想像，使之產製與立法相應的文化想像，並呈現於與文化抗辯相關的認事用法中。

(三) 法官文化想像的趨同與縮放：法律規範的規制力

綜上所述，法官在森林採取、野生動物獵捕與槍枝持有等案件中，受除罪化要件影響，以生活形式來想像具文化意涵的行為類型，形成其文化想像。最後的問題則是：在「除罪化要件影響法官文化想像」的架構下，為何三種案件類型中的法官文化想像，各自與立法想像間形成不同的關係？

82 See SHERENE H. RAZACK, LOOKING WHITE PEOPLE IN THE EYE: GENDER, RACE, AND CULTURE IN COURTROOMS AND CLASSROOMS (1998).

83 從法律文件觀察原住民族與自然環境連結，也關注組織性的、城市的原住民族文化建構如何形塑於法律文件並影響具體權利 See Erika León Angulo, *The Legal Imaginary of "Indigeneity": Creating Knowledge, Subjects, and Law*, 12 OÑATI SOCIO-LEGAL SERIES 945, 965-68 (2022).

為回答此問題，本文先由文化抗辯適用的「案件類型」與「要件理解」間的差異談起。如前所述，案件類型由立法者明確劃出並作為文化抗辯適用的外部界限（區分圖4的A與B），法官缺乏解釋空間而僅能判斷個案是否屬可適用類型，故適用範疇呈現趨同立法而幾無例外的狀況。相對於此，概念上來看，雖然除罪化要件的適用沒有模糊地帶，但法官對要件的理解則存在依其權限解釋適用法律的空間。不過，自實際判決結果觀之，由於法官皆圍繞對要件中「生活慣俗」或「生活工具」等概念的理解進行解釋適用，故依然呈現出受要件影響的情況，使除罪化要件現實上作為文化抗辯適用的內部界限（區分圖4的A1與A2）。簡言之，在法官依立法實證性認事用法的影響下，立法制定的各除罪化規定及其除罪化要件，形成其適用文化抗辯的界限：僅在有除罪化規定的案件類型中適用文化抗辯，並以除罪化要件為解釋適用文化抗辯的框架。

不過，正如圖4對三種案件類型實證觀察的整理，從法官在各類型中對文化抗辯的適用路徑差異切入，可發現文化抗辯適用反映出的法官文化想像，與立法者透過除罪化要件呈現的立法想像間，呈現不同的相互關係：法官對森林採取與野生動物獵捕的文化想像廣於立法想像，法官想像的演進前於立法者；對槍枝持有的文化想像則未廣於立法想像，法官想像框限於立法想像範圍內。

此現象可能是法官解釋適用該要件時，受到該要件影響的效果差異而生。此源自於兩方面的作用：「要件的利益態樣」與「要件的規制強度」，這使得森林法除罪化要件影響法官文化想像（適用文化抗辯範圍）廣於立法者，且該適用類型之後為立法追認而趨同；野保法除罪化要件的狀況類似前者，但法官目前對適用文化抗辯範圍與行為態樣略有分歧，故仍未與立法完全趨同；槍砲條例除罪化要件影響法官文化想像限定於立法想像範圍內。

本文稱此想法為「法律規範的規制力」，亦即在法官受除罪化要件影響其文化想像的前提下，針對法官解釋除罪化要件、決定是否適用文化抗辯與適用路徑的選擇等，假設其行為模式與除罪化要件有所關聯，並具體展現在要件規範的利益態樣及規制強度。但應注意，此想法並非假設立法者主觀上有意透過要件制定引導法官行為，而僅是從法官角度說明其行為客觀上可能受到此規制力的影響。

1. 要件的利益態樣

談到森林採取、野生動物獵捕與槍枝持有使用等犯罪構成要件相關的利益態樣時，直接指涉的當然是各罪的保護法益。從法益的概念史發展看來，刑事法生產與創造知識的過程，正反映現代社會的法律秩序⁸⁴。如立法者根據生態保護與財產法益來形塑違法森林採取罪名⁸⁵，以生態保育與動物保護法益來訂定違法獵捕罪名⁸⁶，與從管制公共危險的角度制定違法槍制持有使用罪名時⁸⁷，宣示法秩序下保護法益之性質。同時，也呈現犯罪行為態樣，如違法持有槍枝為抽象危險犯，而竊取森林產物為實害犯。雖然立法者僅是透過規範制定，來明示法秩序下應保護的利益及應受非難的侵害行為，主觀上可能並未想藉此影響法官文化想像的形塑。但是，從後設的角度觀察法官對這些規範的理解時，這些條文要件指涉的利益態樣，可能成為法官對社會損害程度的詮釋基礎，並間接影響文化想像的形塑。

84 參見許恒達，刑法法益概念的苗生與流變，月旦法學雜誌，197期，頁134-151（2011年）。

85 李桃生，在環境法體系下探討森林法律原則，台灣林業，43卷2期，頁86（2017年）。

86 主張涉及狩獵權與財產權權衡，見：陳新民，最高法院的覺醒——由提出王光祿釋憲案所引發最高法院提出釋憲案的制度與原住民權益保障的法制問題，政大法學評論，155期，頁47（2018年）。從司法院釋字第803號解釋不同法益，見：蔡志偉（Awi Mona）（註30），頁713-725。

87 王皇玉，2012（註7），頁7。

舉例來說，相較於竊取森林產物與獵捕宰殺野生動物等罪名，是以明確得特定的某植物被採取或某動物被獵殺為結果，該侵害範圍具體且可判斷。受訪法官即有提到，非法持有使用獵槍則僅需持有使用等，會對不特定多數人產生安全威脅而具典型公共危險之行為，無須具體侵害結果存在。當法官考量二種不同損害利益態樣的差異，即可能因前者犯行多在採取與獵捕當下即完成，法益侵害範圍較可特定而可控，但後者犯行具持續性，且潛在侵害範圍難以特定且未必可控，而對條文解釋的寬嚴產生影響。亦即，對屬前者行為的文化性質較寬認，採取較開放的文化想像。但對後者除罪化要件解釋則較謹慎，即使所持觀點已較立法階段經濟思維放寬，但實際解釋仍侷限於要件指涉範圍而未寬認行為的文化性質，採較限縮的文化想像。

「槍枝管制畢竟一定是一個一般性的，就是說他可能涉及到個人，不特定多數人的生命財產安全。」(J2)

2. 要件的規制強度

(1)形式上法律規定的解釋空間

要件的規制強度也會影響法官對文化抗辯的解釋適用。而此規制強度有時直接展現於規範明確程度，如當法律明確規定而設下較窄的解釋空間，法官就很難從中提出不同見解。如數位受訪律師所提及：在2019年採取規則制定後，森林法處於「最嚴苛的時代」。由於將薄孔菌屬牛樟芝原則性地明文排除於得採取的森林主副產物外，雖然相較於以往除罪化規定中「生活慣俗需要」的要件更明確，清楚指出採取是否不法的界線，但也讓法官失去考量個案情節來採取不同解釋的空間。換言之，當法條文義明確、解釋空間越窄，對法官的規制強度越高。

「後來15條4項訂出了採取規則之後，反而現在基本上沒有任何除罪化空間。對，那這怎麼會等於是具有除罪化的規範在呢？我覺得很怪，就是你的採取規則裡面就還是要求族人一定要經過許可，那特定族人會採取比如說牛樟芝是絕對原則禁止，例外才允許，可是例外允許幾乎不存在啊。」
(L4)

「林務局的想像是用採取規則放寬原住民，減少他們被處罰的可能吧。但現在沒有啊，現在到法院全部都用採取規則，說：你這些貴重的原則上禁止採取，那你就應該不能採取，然後更何況你還沒經過申請，其實都反而是加嚴了這些……」(L5)

(2)具解釋歧異性的要件數量

接著，形式上的「要件數量」雖非最為關鍵者，但因為可能影響法官對立法者所設要件內涵的理解，仍扮演影響法官文化想像之要素，尤其在要件本身具有解釋歧異性時更顯重要性。例如針對槍砲條例的「供作生活工具之用」，法官對「生活」與「工具」的理解，可能會受二個要件的相互影響：對生活的想像會因「工具要素」，而被限縮範圍至「會使用槍枝的生活」；而對該工具的想像則會受「生活因素」影響，被限縮範圍至「得在預設的生活想像中作為工具」。從「原住民……製造簡易獵槍上山獵捕飛禽走獸……本屬原住民傳統生活方式……」的判決敘述可發現，法官在形塑對應除罪化規定的生活想像時，已將想像對象預設為「會持有使用槍枝的生活型態」，導致除罪化規定僅適用於被預設會攜帶槍枝的狩獵或保護農地等持槍型態。此外，當生活作為工具的修飾性用語，亦即法官設想可適用除罪化規定者為「會用於狩獵生活型態的槍枝」時，自然又會將法官對狩獵的想像帶入槍枝持有有無文化意涵的判斷中。確實，可能因法官對狩獵想像的差異而導致此處意見分歧，

但因雙重要件的相互作用產生較高的規制強度，法官的文化想像仍較難廣於立法範圍，故分歧意見仍被限定在狩獵或農事目的持槍，或可將此理解為一種要件理解層次的文化趨同。

(3)要件實質內涵的設定

雖然規範明確程度與要件數量影響法官文化想像廣狹，但最具影響性的可能是立法者賦予除罪化要件的實質內涵。首先，從法官文化想像廣於立法，爾後又因2019年採取規則制定而產生立法及司法趨同的森林採取談起。在對該行為所設的森林法除罪化規定中，立法者僅設定「生活慣俗需要」此要件。而由後來制定的採取規則定義可知，此要件內涵並未限於需反覆實施而具極強時間性的「傳統文化」，而是將非營利自用的食、衣、住、行、育、樂、醫藥等「生活需要」都涵括在內。可能因為這個要件排除傳統文化具有的歷時性要素，開放地將過往與當代的生活方式都涵蓋於適用範圍，故即使是原住民族傳統未有的生活方式，包括醫療及觀賞娛樂目的之採取，皆屬法官文化想像的內容。

此外，從法院判決提到此森林採取作為生活慣俗時，多會提到原住民族食衣住行與自然環境緊密相連且形成靠山吃山之特殊生活方式，除可發現此要件是以生活方式（而非傳統文化）為判斷核心，也可窺見其對該生活方式應有的空間性，設定「自然環境」此種較寬廣的適用範圍。總結來說，當森林法的除罪化要件具可較廣泛適用的實質內涵時（以生活方式為核心＋無歷時性要求＋空間性要求寬鬆），因其規制程度較低，即可能影響法官產生較廣闊的想像，產生想像範圍廣於立法者的現象。

接著，關於野生動物獵捕，野保法的除罪化規定係以「傳統文化、祭儀」為成立要件。而此要件與森林法除罪化要件的最大差異，在於其並非僅聚焦「生活方式」，而是將「傳統文化」作為立法想像的核心，將原住民族獵捕行為與生活保持距離。若參照「原

住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」(下稱：野保辦法)對傳統文化的定義，雖然原住民族生活內容可涵蓋在文化的範疇中，但能形成傳統者則須「存在於原住民族社會已久，並藉由世代相傳而延續至今」。換言之，此除罪化要件內涵具有強烈的時間性限制，以歷時性要素存在為必要。另外，由「祭儀」觀之，除同樣呈現強烈的歷時性要求，也顯示立法者對獵捕野生動物的文化想像限定於祭典活動與儀式，與以「自然環境」為空間想像的森林法除罪化要件相比，表現出更強烈而緊縮的空間性要求。正因此除罪化要件具較緊縮適用的內涵(以傳統文化為核心+歷時性要求+空間性要求嚴格)，有較高規制程度。所以，雖因該要件並未明確界定何種獵捕屬於傳統文化，保留傳統文化概念判斷上的不明確性，使部分法官仍呈現「從祭儀獵捕擴及至生活中食用獵捕」的擴張想像，但仍有法官想像受影響而限定在立法想像範圍中。

最終，槍砲條例的除罪化要件內涵，可能也與法官文化想像限縮有關。如前所述，作為除罪化要件的「生活」實質上指「原住民會使用槍枝的生活」，而「工具」指「前一要件的生活想像中被使用的工具」。如此一來，除雙重要件在解釋上相互影響，使法官透過對「會使用槍枝的生活中，將槍枝作為工具使用的形式」的限縮想像，判斷持有槍枝是否適用除罪化規定。若由法官常以「傳統生活方式」的敘述來正當化原住民族持槍行為觀之，「傳統」概念帶有的歷時性因素經常被放入文化想像的形塑，都可能是與法官僅將狩獵與保護農地作為合法持槍目的相關的因素。當法官文化想像被除罪化規定影響而限縮，自然不會產生擴及立法想像範圍外的狀況，也就呈現判決集中於無罪路徑的情形。

伍、結論

本文在現有文化抗辯外國理論的引介，與法解釋學對此理論如何適用的討論基礎上，嘗試納入法律實踐的面向，探問當臺灣繼受歐陸法體系，而存在異於該理論母國俱為壟殖者國家型態的發展脈絡下，呈現出何種文化抗辯的適用樣貌，及該樣貌的形塑機制為何（本文貳）。結合判決分析與訪談資料，本文發現雖然臺灣原住民族與國家法制的文化衝突型態多元，但文化抗辯適用卻侷限於立法除罪範疇，僅已立法制定除罪化規定的森林採取、野生動物獵捕與槍枝持有等案件類型有適用文化抗辯的可能。換言之，案件類型層次呈現出法院文化想像完全趨同立法的現象（本文參）。此外，本文也發現在設有除罪化規定的案件類型中，法官對除罪化要件的理解會因案件類型而有別。如森林採取與野生動物獵捕，呈現出法官文化想像廣於立法的現象，反之槍枝持有的法官文化想像則被框限於立法想像中。而此現象也引導法官最終判決路徑的選擇。對於要件理解層次中，法官文化想像趨同於立法程度不一的現象，本文認為源自於法律規範的規制力，可能是在受各除罪化規定引導時，因要件的利益態樣與規制強度所致（本文肆）。總結全文，以花蓮地院為起點，本文初探在法院適用文化抗辯時，呈現「案件類型完全趨同立法；要件理解受法規範規制力影響而有趨同程度差異」的本土現象。而且，與理論母國因司法實踐形成文化趨同有異，我國是在規範的立法與法院實踐交織的相互作用中，形成前述現象。

上述觀察說明了，與法院實踐搭配的除罪化規定，作為影響法官案件適用、要件解釋與判決路徑選擇的因素，在文化抗辯形塑機制中扮演重要角色。若從循證決策（evidence-based policy）的角度觀之，此觀察帶來的政策意義有二：

第一，除了如司改國是會議反覆檢討的司法人員文化教育與審判制度改革外，法律規範會是當前檢討重心。除了對現行制定除罪

化規定的案件類型、除罪化要件內容的再思考，如何與不斷推陳出新的其他法規（如採取規則、野保辦法）、大法官解釋、憲法訴訟判決搭配，都需要綜合考量。如當法官有依立法實證性認事用法的傾向，使法律規範有影響法官行為的可能時，為合理擴大文化抗辯適用範疇，避免間接抗辯難為法院接受，即有受訪法官認為應直接透過立法途徑處理：

「就是解釋的技術上面不能達成……解釋技術上面過於複雜、反覆的時候，立法者是不是要設定一個要件去處理這個問題？我覺得那很重要，因為你直觀上面，法院在……容許構成要件錯誤的時候已經很極限。」（J2）

舉例來說，當太魯閣族實際上仍保有為食用而獵捕野生動物的習慣，且該習慣在國家保育政策壓縮之下仍有效維持於相關獵區時⁸⁸，既然實證所得法現象顯示法官也普遍認為食用目的之獵捕可適用文化抗辯，只是因欠缺明文而未能判決無罪。那麼，將「食用」明文訂入野保法的除罪化規定，即是政策的可行方向。

第二，配合原住民族文化慣習的相關調查，調整除罪化規定來使法院合理適用文化抗辯，雖然是可能的發展方向。但正如有訪談律師提醒，立法制定或修正除罪化規定的方式，可能反而產生限縮文化抗辯適用的結果：

「當你立法立得不好，或者是立法立得又太限縮的時候，反而因為一立法那個除罪化的可能性就完全不見了，那個空間就消失了。」（L4）

詳言之，從「國家法（立法）vs法院vs部落規範（原住民族）」的整體脈絡來看，透過立法途徑來影響法官文化抗辯適用的

88 戴興盛、莊武龍、林祥偉，國家野生動物保育體制、社經變遷與原住民狩獵：制度互動之太魯閣族實證分析，台灣政治學刊，15卷2期，頁36-41（2011年）。

政策方向，可能只單純從國家本位來思考，僅聚焦在立法與法院的關係中文化抗辯的意義，卻忽略原住民族與二者互動過程中文化抗辯對原住民族的意義。如此一來，只著眼「立法vs法院」面向的政策進路，可能無法完整觀察部落規範與國家間的互動，使立法修訂的除罪化規定及法官依立法實證性所為之決定，顯現與實況未盡相符的文化想像，難以形成合理的文化抗辯適用範圍，甚且使刑法保護法益目的落空。例如，即使將食用目的之獵捕明文制定於除罪化規定，其他遵守部落獵區規範的文化實踐依舊未能適用文化抗辯。而且，如太魯閣族獵區規範受國家法壓制的理由是生態保育，但實證研究指出這導致原住民族退出獵區管理，當國家降低監管時，反而使該區域生態保育承受更高侵害風險。換言之，採「原則施加刑罰，例外除罪」的現行政策模式時，保障多元文化與生態保育等目的可能全面落空。對此，若從只關注「法院vs立法」的現行政策模式可能有忽略衝突脈絡、未將行為人視為本質上主體的問題來看⁸⁹，納入原住民族視野，可能產生完全不同的政策想像。例如，廢除現行模式而選擇行政管制，以狩獵自主管理方式進行實質共管，或許是保障多元文化且落實生態保育的更佳政策方向。

總結來說，雖然上述政策意義如何具體發展與實際規劃，非本文篇幅可處理，但在肯定立法扮演重要機制的前提下，未來討論重點自不在「是否」，而在應「如何」修（立）法。而這也是本文後續研究的走向：作為初步奠基作品，本文僅針對單一法院初探現況，作為探討政策發展與梳理問題意識的基礎，發掘有待未來深入的課題。對此，未來一方面會將觀察對象由法官（人）擴及於法庭（制度，如分案設計、證據法則），一方面會將觀察視野擴及全國法院，期望藉此提供決策時更具說服力的法理推論與政策評估。

⁸⁹ Louk Hulsman, *The Abolitionist Case: Alternative Crime Policies*, 25 ISRAEL L. REV. 681, 683-84 (1991).

參考文獻

1. 中文部分

- 王皇玉（2007），文化衝突與臺灣原住民犯罪困境之探討，臺大法學論叢，36卷3期，頁255-304。
- （2009），原住民犯罪的文化困境與除罪化，收於：刑罰與社會規訓——台灣刑事制裁新舊思維的衝突與轉變，頁205-250，臺北：元照。
- （2009），原住民犯罪與不法意識之研究——兼評新竹縣尖石鄉風倒木竊取案件，收於：刑罰與社會規訓——台灣刑事制裁新舊思維的衝突與轉變，頁251-279，臺北：元照。
- （2012），原住民持有槍械問題之研究，台灣原住民族研究季刊，5卷1期，頁1-37。
- （2016），原住民犯罪的文化抗辯及其實踐，臺灣原住民族法學，1卷1期，頁31-44。
- 王泰升（2015），台灣法律史上的原住民族：作為特殊的人群、地域與法文化，臺大法學論叢，44卷4期，頁1639-1704。
- （2015），論台灣社會上習慣的國家法化，臺大法學論叢，44卷1期，頁1-69。
- （2022），建構台灣法學：歐美日中知識的彙整，臺北：臺大出版中心。
- 王鵬翔（2005），論基本權的規範結構，臺大法學論叢，34卷2期，頁1-61。
- （2007），規則、原則與法律說理，月旦法學教室，53期，頁74-83。
- 何漢葳（2021），應作迴歸觀：資料、不確定性與人工智慧法學，收於：李建良編，研之得法：中央研究院法律學研究所成立十

- 週年文集，頁721-743，臺北：中央研究院法律學研究所。
- 吳聰敏（2023），台灣經濟四百年，臺北：春山。
- 李桃生（2017），在環境法體系下探討森林法律原則，台灣林業，43卷2期，頁80-87。
- （2020），原住民族利用森林資源權利論——回顧與展望，台灣林業，46卷2期，頁41-58。
- 范耕維（2022），森林法第15條第4項傳統領域概念之適用與檢討：評最高法院109年度台上字第3148號刑事判決及其歷審判決，法律扶助與社會，9期，頁25-56。
- 夏曉鵬（2010），失神的酒：以酒為鑑初探原住民社會資本主義化過程，台灣社會研究季刊，77期，頁5-58。
- 張永健（2013），分割共有物判決之實證研究，收於：張永健編，2011司法制度實證研究，頁221-264，臺北：中央研究院法律學研究所。
- （2014），越界建築訴訟之實證研究，中研院法學期刊，14期，頁319-373。
- （2019），實證研究在法學中的角色，收於：法實證研究：原理、方法與應用，頁49-113，臺北：新學林。
- 張宏節（2018），非法獵捕保育類野生動物判決之實證研究——以原住民文化抗辯為中心，法律扶助與社會，1期，頁31-69。
- 陳湘繁（計畫主持人）（2021），盜伐歷史資料統計分析項目應用於竊取森林主副產物犯罪問題與防治研究計畫，委託研究計畫期末報告，臺北：行政院農業委員會林務局。
- 陳新民（2018），最高法院的覺醒——由提出王光祿釋憲案所引發最高法院提出釋憲案的制度與原住民權益保障的法制問題，政大法學評論，155期，頁1-58。
- 許恒達（2011），刑法法益概念的茁生與流變，月旦法學雜誌，197期，頁134-151。
- （2013），國家規範、部落傳統與文化衝突——從刑法理論

- 反思原住民犯罪的刑責問題，台灣原住民族研究季刊，6卷2期，頁33-82。
- （2016），刑法秩序與多元文化：以東亞刑事法院為中心的考察，收於：葉俊榮編，變遷中的東亞法院：從指標性判決看東亞法院的角色與功能，頁107-146，臺北：臺大出版中心。
- （2017），持有獵槍、獵捕保育類野生動物與原住民慣習間的衝突及解套：評宜蘭地方法院104年度原訴字第1號刑事判決，臺灣原住民族法學，1卷2期，頁49-60。
- 湯文章（2005），原住民族在訴訟法上地位之研究，憲政時代，31卷1期，頁35-59。
- 雅柏甦詠·博伊哲努（Yapasuyongu Poiconu）、楊曉珞（2012），文明社會的野蠻誠命：從嘉義地方法院九十二年度簡上字第一五一號判決談鄒族傳統財產權，台灣原住民族研究季刊，5卷3期，頁121-156。
- 樓一琳（2021），原住民族文化抗辯於我國刑事司法體系之應用兼論原住民族司法諮詢委員會之地位，臺灣原住民族法學，7期，頁112-131。
- 蔡志偉（Awi Mona）（2011），從客體到主體：臺灣原住民族法制與權利的發展，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1499-1550。
- （2016），民族法主體之建立：臺灣原住民族自治之視角，臺灣原住民族法學，1卷1期，頁77-86。
- （2022），從「王光祿釋憲案」論原住民族狩獵文化權利的憲法保障，臺大法學論叢，51卷3期，頁685-755。
- 戴興盛、莊武龍、林祥偉（2011），國家野生動物保育體制、社經變遷與原住民狩獵：制度互動之太魯閣族實證分析，台灣政治學刊，15卷2期，頁3-66。
- 謝孟羽、張靖珮（2018），臺灣原住民族之法律扶助，2018法律扶助國際論壇，財團法人法律扶助基金會主辦，2018年11月1日至11月3日。

顏厥安(1998)，法與實踐理性，臺北：允晨文化。

———(2002)，規則、理性與法治，臺大法學論叢，31卷2期，頁1-58。

2. 外文部分

Angulo, Erika León. 2022. The Legal Imaginary of “Indigeneity”: Creating Knowledge, Subjects, and Law. *Oñati Socio-Legal Series* 12:945-980.

Cane, Peter, and Herbert M. Kritzer. 2010. Introduction to *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, edited by Peter Cane and Herbert M. Kritzer. New York, NY: Oxford University Press.

Coleman, Doriane. 1996. Individualizing Justice through Multiculturalism: The Liberals’ Dilemma. *Columbia Law Review* 96:1093-1167.

Demian, Melissa. 2008. Fictions of Intention in the “Cultural Defense”. *American Anthropologist* 110:432-442.

D’hondt, Sigurd. 2010. The Cultural Defense as Courtroom Drama: The Enactment of Identity, Sameness, and Difference in Criminal Trial Discourse. *Law & Social Inquiry* 35:67-98.

Dworkin, Ronald. 1978. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fischman, Joshua B. 2013. Reuniting ‘Is’ and ‘Ought’ in Empirical Legal Scholarship. *University of Pennsylvania Law Review* 162:117-168.

Galanter, Marc. 1981. Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 13:1-47.

Good, Anthony. 2008. Cultural Evidence in Courts of Law. *Journal of the Royal Anthropological Institute* 14:S47-60.

- Hulsman, Louk. 1991. The Abolitionist Case: Alternative Crime Policies. *Israel Law Review* 25:681-709.
- Jackson, Jean E. 2019. *Managing Multiculturalism: Indigeneity and the Struggle for Rights in Colombia*. Redwood City, CA: Stanford University Press.
- Kritzer, Herbert M. 2021. *Advanced Introduction to Empirical Legal Research*. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- Lawless, Robert M., Jennifer K. Robbennolt, and Thomas S. Ulen. 2009. *Empirical Methods in Law*. New York, NY: Aspen.
- Lee, Cynthia. 2007. Cultural Convergence: Interest Convergence Theory Meets the Cultural Defense. *Arizona Law Review* 49:911-959.
- Mather, Lynn. 2011. Law and Society. Pp. 289-304 in *The Oxford Handbook of Political Science*, edited by Robert E. Goodin. New York, NY: Oxford University Press.
- Phillips, Anne. 2007. *Multiculturalism without Culture*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Razack, Sherene H. 1998. *Looking White People in the Eye: Gender, Race, and Culture in Courtrooms and Classrooms*. Toronto: University of Toronto Press.
- Renteln, Alison D. 1993. A Justification of the Cultural Defense as Partial Excuse. *Southern California Review of Law and Women's Studies* 2:437-526.
- . 2004. *The Cultural Defense*. New York, NY: Oxford University Press.
- Sams, Julia P. 1986. The Availability of the “Cultural Defense” as an Excuse for Criminal Behavior. *Georgia Journal of International and Comparative Law* 16:335-354.
- Sisk, Gregory C. 2008. *The Quantitative Moment and the Qualitative Opportunity: Legal Studies of Judicial Decision Making* (book

review). *Cornell Law Review* 93:873-900.

Upton, J. Christopher. 2022. From Thin to Thick Justice and Beyond: Access to Justice and Legal Pluralism in Indigenous Taiwan. *Law & Social Inquiry* 47:996-1025.

Volpp, Leti. 2000. Blaming Culture for Bad Behavior. *Yale Journal of Law and the Humanities* 12:89-116.

A Preliminary Exploration of the Application and Significance of Cultural Defenses in Taiwan's Indigenous Criminal Cases:

Empirical Legal Research in Hualien District Court

*Keng-Wei Fan** & *Jun-Ru Lin***

Abstract

This article focuses on the Hualien District Court as its observational subject, conducting an initial investigation into how judges in Taiwan's criminal trial system decide on the application and scope of cultural defenses when faced with claims or relevant provisions brought forth by indigenous defendants. It aims to clarify how the current legal framework shapes judges' application of cultural defenses and its normative significance. In other words, this article shifts its focus from theoretical introduction to the observation and interpretation of legal practices.

Firstly, through the analysis of judgments and interviews with judges and lawyers, this article finds that despite the diverse cultural conflict patterns between indigenous peoples and the national legal system, the application of cultural defenses is confined to specific case types for which legislators have already established decriminalization rules. In terms of case types, it appears that the judicial cultural imagination aligns entirely with the legislature. Furthermore, within case types with established decriminalization rules, this article also discovers

* Associate Professor, Department of Law, National Dong Hwa University.

** Ph.D., College of Law, National Chengchi University.

that judges' understanding of the rule's criteria may vary depending on the case type. Moreover, such differences influence judges' decision-making paths when applying cultural defenses, leading to a choice between mitigating sentences or acquittal. The article posits that these variations in cultural interpretation and application of cultural defenses can be attributed to the varying degrees of the regulation of legal norms within these specific case types. Factors that contribute to this variation include the nature of the criteria's protective interests, the clarity of legal provisions, the quantity of criteria, and the substantive content of the criteria. In conclusion, this paper argues that the development of cultural defense is shaped through the interaction between internal practices in the courtroom and legislature. It differs from the development in its theoretical homeland, forming a practical and theoretical construct with distinctive local characteristics.

KEYWORDS: cultural defense, indigenous peoples, cultural convergence, forest collection, wildlife hunting, firearm possession, empirical legal research, law and society.